

合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十四条的释义,一审法院对某管理服务公司以工程存在质量问题验收不合格、付款条件未成就为由拒绝付款之辩解不予采纳,某管理服务公司应自场地交付时视为满足验收条件并按合同约定在次月内付至结算总价97%,现某管理服务公司逾期付款的行为亦属违约。

广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百七十九条、第五百八十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十二条第一款之规定,判决如下:

一、某管理服务公司向某装饰工程公司支付工程款316012.13元及暂计至2022年8月31日的逾期付款损失4709.01元,之后的损失以尚欠工程款本金为基数,按年利率3.7%继续算至某管理服务公司实际清偿之日止;

二、驳回某装饰工程公司的其他诉讼请求。

某管理服务公司不服一审判决,提起上诉。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为:争议焦点为一审关于工程价款的认定有无依据。

法院认为,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十四条之规定,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,人民法院不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。本案中,双方并未进行最后竣工验收,但某管理服务公司已将案涉工程交由他人实际使用,依法应自场地交付使用时视为满足合同约定的验收条件,上诉人应按合同约定在次月内付至结算总价97%,一审对其以工程存在质量问题为由拒绝付款的辩解不予采纳于法有据。

法院认为上诉人某管理服务公司的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

对于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后的责任承担已有明确的法律规定，但对于装饰装修是否纳入建设工程范围，一直存在争议。对此，本案在区别不同类型的装饰装修工程基础上明确不同的责任承担规则。

一、装饰装修工程的不同类型及法律适用

《中华人民共和国建筑法》第二条第二款规定的建筑活动中，并未提及装修。但根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程包括装修工程。在《最高人民法院关于装饰装修工程款是否享有合同法第二百八十六条规定的优先受偿权的函复》中，也曾表示“装饰装修工程属于建设工程”。对此，从体系解释来看，《建设工程质量管理条例》第二条第二款虽然将装修工程涵盖在建设工程范围内，但《住宅室内装饰装修管理办法》第四十五条规定，住宅竣工验收合格前的装饰装修工程管理，按照《建设工程质量管理条例》执行，显然，住宅竣工验收合格后的装饰装修工程是未被纳入其中的。现实中，在竣工验收交房后一般业主的住宅室内家装，规模较小，难度不高，往往不涉及公共安全等因素，故多是由没有资质的个体装修从业者实施，假如都纳入建设工程范围，必然难以符合建设工程相关法律法规规定的施工人资质、竣工验收等方面的严格规范，这不但符合实践需求，也将导致相应从业市场的萎缩，不符合建筑立法维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全的立法价值。所以，对于装饰装修工程是否属于建设工程，应当从两个方面进行判断：

第一，是否是住宅竣工验收合格后的装饰装修工程，假如是，则可能被排除在外。

第二，需审查房屋的性质与用途、设计工程的规模、合同约定的具体内容及难易程度、是否涉及公共安全等因素。假如包括土建工程施工中建筑主体和承重结构变动等，尤其是针对工商业及公共场所的装饰装修，即使是竣工验收合格后进行的装饰装修工程，也应当纳入建设工程范围。

二、对于装饰装修工程未经竣工验收即使用的规则适用

(一)属于建设工程的装饰装修工程的规则适用

装饰装修被纳入建设工程范围的，应当适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十四条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

本案中，涉案装修工程范围较大且涉及公共范围的使用，故应当纳入建设工程范围。发包方已提前允许租户使用场地，故对于主体工程之外的质量问题不能再主张相应权利。

(二)对于未纳入建设工程范围的装饰装修工程的规则适用

目前现实中，大部分家庭装饰装修工程为业主自行委托，且对施工人员也无严格的资质要求，并无严格的竣工验收标准、程序规范。基于家庭需要在装修完成前提前使用，后续继续装修其余部分的现象也不少见，使用过程中发现质量问题需要整改的情况较为普遍，为此，不应对家庭装饰装修的业主过多苛责，不能仅因为未经验收而使用就将工程质量责任风险转移给业主。

编写人：广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院 韦茜茜

足额缴纳社会保险不当然认定存在劳动关系

——房某诉某建设公司建设工程施工合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终5302号民事判决书

2. 案由：建设工程施工合同纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、上诉人):房某

被告(反诉原告、上诉人):某建设公司

【基本案情】

2017年7月13日,招标人征迁工作领导小组综合办公室向某建设公司发出《中标通知书》,确认某建设公司为案涉工程中标人,后由指挥部办公室与某建设公司签订《房屋拆除委托协议书》(拆除规模约289200平方米,每平方米拆除费用5.5元)。2018年9月15日,某建设公司作为甲方与房某作为乙方签订1份《项目投资合作协议书》,约定某建设公司将其中标的案涉房屋拆除工程交由房某施工。协议书主要内容:乙方向甲方支付50万元(其中20万元为项目利润保证金;另30万元为履约保证金,由乙方承担,甲方代转发包人,待发包人退还保证金后,甲方在5个工作日内退还乙方),乙方向甲方上缴利润110万元整(甲方收取1元/平方米作为管理费用),等等。协议签订后,房某先后向某建设公司指定的账户转账支付合计50万元。后由于施工进度、质量安全无法达到发包方的要求,业主指挥部办公室向某建设公司发出房屋拆除委托关系解除通知书。2019年12月10日,房某组织工人离场。据统计,房某于2018年6月13日开始组织施工,完成拆除房屋125658.67平方米,对应工程价款565464.02元(双方均认可按每平方米4.5元计算)。

房某认为,双方之间形成转包合同关系,因其不具有承包建设工程的资质,违反了法律强制性规定,应认定为无效合同。请求某建设公司立即退还保证金并支付工程价款及资金占用期间的利息损失。

某建设公司在审理中提起反诉并认为,房某受其公司聘用担任案涉施工项目的现场管理人员,其公司亦为其缴纳相应的社会保险。且房某在另案亦表示其于2018年5月22日入职公司,故双方形成劳动关系。而案涉项目投资合作协议约定公司将案涉项目的施工管理任务以内部承包方式交由房某具体负责,并对双方的权利和义务、付款、结算办法和违约责任等进行了明确约定,属于

内部承包合同关系。该协议系双方真实合意，依法有效，各自应全面履行，故请求：1. 房某支付其利润110万元及资金占用期间的利息损失；2. 以案涉项目保证金50万元补偿其遭受的经济损失。

【案件焦点】

1. 房某与某建设公司之间是否存在劳动关系；2. 双方签订的《项目投资合作协议书》是否属于建设工程内部承包合同的问题。

【法院裁判要旨】

福建省泉州市泉港区人民法院经审理认为：某建设公司虽然提交证据证明其为房某缴纳了社会保险，但房某否认双方间存在劳动合同关系，某建设公司未能提交其他证据证实双方之间确实形成管理与被管理的隶属关系，某建设公司主张双方存在劳动关系，依据不足，难以认定；从案涉协议书中双方约定的具体权利义务看，某建设公司只收取管理费和利润款，未在资金、技术、设备、人力等方面提供支持，因此，双方间实际上形成工程转包合同关系。因房某不具备施工资质，违反法律强制性规定，上述协议书应认定为无效。合同无效后，房某有权要求某建设公司退还已支付的履约保证金30万元及资金占用期间利息损失。房某已完成部分施工，其有权要求某建设公司支付对应的工程价款565464.02元及资金占用期间利息损失。某建设公司要求房某支付其利润款110万元，但未能提供证据证实，不予支持。但其确实存在一定的损失，综合考虑案涉工程为房屋拆除项目特点、已完成的拆除面积数量和双方的过错程度等，房某已支付给某建设公司的利润保证金20万元，可不予以返还，用于补偿某建设公司的经济损失。

福建省泉州市泉港区人民法院判决：

一、某建设公司支付房某工程价款565464.02元、返还履约保证金30万元及相应资金占用期间利息损失；

二、房某以已支付的利润保证金20万元补偿某建设公司的经济损失；

三、驳回房某的其他诉讼请求；

四、驳回某建设公司的其他反诉诉讼请求。

双方均不服一审判决，提起上诉。

福建省泉州市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

企业内部承包是一种生产经营模式的激励机制创新，本身不为法律所禁止。其主要特征有：一是内部承包合同主体之一的内部承包人必须是施工企业的在职职工或下属分支机构；二是内部承包人与施工企业之间有统一的财务管理，这是企业内部财务制度的统一性和账目登记的完整性的需要；三是内部承包情况下，施工企业对外负担项目的亏损，在内部承包人会因管理不善受到一定的经济处罚。从现行规定以及司法判例来看，内部承包合同本身为有效合同，但实践中时常出现一些施工企业以“内部承包”之名行违法转包、挂靠之实。因此，区分内部承包与内部承包虚假名义下的“转包”“挂靠”，显得尤为重要。

一、关于内部承包与内部承包虚假名义下的“转包”

内部承包是施工企业将承包的部分或全部工程转给本单位的分支机构或在册员工，并签订内部承包协议，内部合法有效，企业对外承受权利义务。而内部承包虚假名义下的“转包”，主要是指施工企业将所承包的工程部分或全部交由与其无任何隶属关系的主体承包施工，属于违法行为，依法归于无效。所以，判断承接主体与施工企业之间的关系是区分二者的关键。

二、关于内部承包与内部承包虚假名义下的“挂靠”

“内部承包”形式的挂靠，系由被挂靠企业任命或聘用挂靠的自然人为其职员并委以职务，双方再签订“内部承包合同”，以“内部承包”名义行挂靠之实。二者本质的区别，在于招投标及与发包人签订施工合同的参与度以及承接主体与施工企业之间的隶属关系。一般的内部承包，招投标及与发

包方签订 建筑施工合同完全由施工企业负责，下手的内部承包主体只参与后续工程的承接施工；而挂靠则不然，系全程深度代替性参与。

以上,不难看出,内部承包虚假名义下的“转包”“挂靠”,均可能存在虚构劳动关系(隶属关系)以掩盖非法目的情形。《全国法院民商事审判工作会议纪要》指出要“通过穿透式审判思维,查明当事人的真实意思,探求真实法律关系”。

劳动者人格及经济从属性是认定劳动关系最核心的标准。笔者认为,认定劳动关系必须采取综合认定的方法,即劳动关系应该根据劳动者是否实际接受用人单位的管理、指挥或者监督,劳动者提供的劳动是否属于用人单位业务的组成部分,用人单位是否向劳动者提供基本劳动条件,以及向劳动者支付报酬等因素综合认定。具体来讲,对于用人单位未与劳动者订立书面劳动合同的,应当综合考虑下列情形认定双方之间是否存在劳动关系:(1)劳动者实际接受用人单位的管理、指挥与监督。(2)用人单位有向劳动者支付过工资性劳动报酬的记录,劳动者在经济上依赖于用人单位。(3)劳动者被纳入用人单位的生产组织体系中从事劳动,而不是从事独立的业务或经营活动。(4)劳动者无权将工作分包给他人完成。(5)劳动工具、原材料一般由用人单位提供。(6)工作时间、场所一般由用人单位决定或受其控制。(7)劳动者只为一个用人单位提供劳务。(8)劳动者提供的劳务是继续性的而不是一次性的。(9)劳动者向用人单位提供较为长期、固定的劳务。当然,由于劳动关系本身的特殊性和复杂性,认定当事人之间是否存在劳动关系,上述标准并非绝对,还需要结合具体情况加以分析。在具体的证据审核认定上,可以参照原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第二条第一款所规定的凭证进行判断,即:(1)工资支付凭证或记录(职工工资发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录;(2)用人单位向劳动者发放的“工作证”“服务证”等能够证明身份的证件;(3)劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”“报名表”等招用记录;(4)考勤记录;(5)其他劳动者的证言等。因此,足额缴纳社会保险仅是认定劳动关系的一个参考因素,而非决定因素,法官不应拘泥当事人之间的合同形式乃至合同名称来认定双方法律关系,而应运用“穿透式审判思维”从实质特征进行判断。

具体到本案，某建设公司以公司为房某缴纳社保费用为由主张双方存在劳动关系，虽房某在另案曾自述其为该公司职员，但在本案中又予以否认，并对其在另案所作自述相应事实进行了合理解释说明，在未能进一步提供管理、考勤等证据佐证双方之间确实形成管理与被管理的隶属关系的情况下，法院对某建设公司的主张不予采纳。本案系通过“穿透式审判思维”，深入探究查明当事人的真意，探寻真实的法律关系，整体评判案件全貌，合理公平地确定举证责任，对欲借内部承包之名行违法之实予以否定，进而最终恢复规则背后应有的实体公正和秩序价值，达到矛盾纠纷实质性化解的目的，充分发挥了司法裁判的规则引领和价值导向功能。

编写人：福建省泉州市泉港区人民法院 叶绿莹 张秀灵

实际施工人的原告主体资格认定标准

——林某诉某仓储物流公司建设工程合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省揭阳市中级人民法院(2023)粤52民终292号民事裁定书

2. 案由：建设工程合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 林某

被告(被上诉人): 某仓储物流公司

第三人: 某建设公司揭阳分公司、蔡某、张某

【基本案情】

2020年9月25日，发包人某仓储物流公司与张某挂靠的某建设发展公司签订了《消防施工分包合同》，工程为某综合楼，总造价为168万元。张某因其没有消防资质，与某仓储物流公司还有其他生意合作，经蔡某介绍认识林某，张某委托林某、蔡某共同管理涉案工程。

2020年9月至11月期间，林某与孙某等人签订了《劳务分包合同》，将涉案综合楼的消防工程分包给其施工；与深圳某某公司签订了《销售合同》，向该公司购买消防报警设备；与上海某某公司签订了设备《租赁合同》，向该公司租赁高空作业平台；与被挂靠方第三人某建设公司揭阳分公司签订了仓储物流园资质使用合同。

同年12月某仓储物流公司与某建设公司揭阳分公司签订了《消防工程施工合同》，某仓储物流公司决定将项目钢结构消防安装工程发包给某建设公司揭阳分公司施工，某建设公司揭阳分公司委派现场人员林某与某仓储物流公司对接工作。2021年1月某仓储物流公司法定代表人黄某与林某在工程结算清单（总）上签名确认，清单主要内容是：总工程量包工、包料造价总金额为2533050元，双方签名确认并与合同同时生效，现移交某仓储物流公司使用及管理。第三人张某夫妻确认已支付涉案工程款160多万元，是通过微信、银行转账或现金支付给林某、被挂靠公司、材料厂家、风管商家、孙某等劳务人员。

林某主张某仓储物流公司尚欠其工程款2533050元及后续增加部分工程的工程款198060元，合计2731110元，经林某催讨，某仓储物流公司拒绝付款。林某提起民事诉讼，请求法院：判决某仓储物流公司向林某支付工程款项1053471.93元。

【案件焦点】

林某是否为实际施工人，是否具有原告主体资格，是否有权追索工程款。

【法院裁判要旨】

广东省揭阳市揭东区人民法院经审理认为：林某挂靠的某建设发展公司、

某建设公司揭阳分公司与被告某仓储物流公司签订涉案工程的承包合同，由林某作为发包人将工程分包给其他人承包，并由其与被告进行工程结算，但张某在工程施工过程中履行了实际承包人的职责和义务，而林某在工程施工过程中也只是履行了管理人的职责，并没有履行实际承包人的职责和义务，也不是实际施工人。林某不是本案适格原告，其无权向被告主张权利。

广东省揭阳市揭东区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条和第一百一十九条之规定，判决如下：

驳回林某的诉讼请求。

林某不服一审判决，提起上诉。

广东省揭阳市中级人民法院经审理认为：林某是否为本案适格原告，只有举证证明其构成实际施工人，才有权追索工程款。林某提供了施工合同、结算单、客户收款回执、送货单、材料结算证明等证明案涉工程合同、单据由其作为某建设公司揭阳分公司的代表与某仓储物流公司签订并持有，由其管理，但未能提供相应的施工记录、工程签证单、领款单、工程请款单、工程验收单等施工过程中产生的凭证材料，以证明由其实际施工、请款等事实，且某仓储物流公司否认结算金额，并要求与张某结算。另，张某提供了涉案工程的工程款、材料款、购买消防设备、风管、劳务费、租赁设备等费用系其与妻子支付的凭证，且提供微信聊天记录证明张某有实际指挥、管理施工，并指示林某付款或直接支付给挂靠方，再转支给材料供应商等垫付及预支工程款的情况。再者，林某尚未能有效举证其最终实际投入资金、材料和劳动力，并对案涉工程享有独立支配权，有实际施工行为，履行施工合同义务。本院根据高度盖然性的证明标准，认定林某不是本案适格原告，对不属于实际施工人范围的当事人以发包人为被告主张欠付工程款的，已经受理的，应当裁定驳回起诉。

广东省揭阳市中级人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十八条之规定，裁定如下：

一、撤销广东省揭阳市揭东区人民法院(2021)粤5203民初2476号民事判决；

二、驳回林某的起诉。

【法官后语】

本案重点探讨在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》实施后,审判中如何从严把握实际施工人的认定标准,甄别并剔除不构成实际施工人的主体,以期为统一裁判标准提供审判样本。

一、我国实际施工人制度的发展脉络

2004年《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(已失效)出现“实际施工人”这一说法,但没有明确其内涵及外延。2018年《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》(已失效)规定了“实际施工人”的范围仅包括转包和违法分包,没有明确借用资质的情形。通过分析三部审理建工合同司法解释的发展过程,使用“实际施工人”一词,意指无效合同中最终实际投入资金、材料和劳动力进行施工的法人、非法人团体、个人合伙、自然人等。实际施工人一般具有民事权利能力和民事行为能力,但实际施工人不具有从事建筑工程施工的从业资质资格,实际施工人不是法律规定从事建设工程业务的合法市场主体,其从事工程施工转包、违法分包行为为无效民事行为。^①通常认为,实际施工人在建设工程实践中主要有三种表现形式,即转包人、违法分包人、借用资质的挂靠承包人。实务中倾向认为,对2020年《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第四十三条解释的适用问题应当从严把握,该条款只规定转包和违法分包两种类型,不包括挂靠型,实际施工人不属于与发包人订立建设工程施工合同的承包人,不享有建设工程价款优先权。

二、甄别实际施工人的主体资格

第49页。

在建筑行业中，施工班组通常被认为是劳务单位或包工头个人在组织施工

①李恒、马凤玲：《建设工程法律制度与实务技能》（第3版），法律出版社2021年版，

过程中将钢筋工、木工、瓦工、电工等相同工种组织在一起形成最小施工单元。①施工班组长与实际施工人之间是劳动关系或劳务关系，施工班组长并非实际施工人，通常仅为建筑工人的代表，对农民工实施管理的中间人，究其原因施工班组没有实际投入资金、没有实际指挥管理、没有承担项目盈亏的风险，无自主控制权。本案的林某无法证明其为实际施工人，但其确实参与工程项目的具体管理，甚至作为代表在施工合同签字、出面以其名义购买设备、材料、租赁设备、雇佣工人等组建施工单元，更像是“施工班组长”。实践中，实际施工人雇佣施工班组长作为某个项目的负责人或名义上“挂名人”“代理人”委任其代为从事市场活动，能有效规避经营风险，隐藏自己的身份，如此表里不一极易导致索款主体之争。

三、穿透实际施工人认定标准

实际施工人要证明其符合实际施工人身份，需证明案涉工程实际所需的人力、物力、财力都是由其独立负责并承担，自证其身份往往要形成完整证据链。人民法院审理此类“挂名”案件应注意透过现象看本质，探究当事人的真实意思表示，结合实际施工人的法律特征以及投入成本综合判断。

该案体现从“外观主义”过渡到“穿透式审判”的裁判理念，探索了能动司法的积极意义，追求实质正义，不机械适用外观主义的圭臬。

编写人：广东省揭阳市中级人民法院 曾舒扬

①史鹏舟、徐寅哲、雷涛、杨峰：《建设工程实际施工人法律问题深度解析》，法律出版社2022年版，第46页。

十四、运输合同纠纷

30

物流公司未尽到提示说明义务或不合理免除 或减轻自身责任的保价条款无效

——舒某诉某运输公司运输合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终7849号民事判决书

2. 案由：运输合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 舒某

被告(上诉人): 某运输公司

【基本案情】

某运输公司系从事城市配送运输服务的公司。舒某注册某运输公司的应用程序后，于2022年3月21日通过该应用程序下单运送绿松石项链，运费为15.3元，并未选择保价服务。某运输公司派件员完成取件后于一个多小时后告知舒某货物丢失。某运输公司将舒某所支付的运输费退还，但以舒某未选择保价服务为由拒绝赔偿因绿松石项链丢失给舒某所造成的损失。

经查，舒某在注册案涉应用程序时需同意《服务用户协议》，该协议中约定：费用是按照物品的重量收取的服务费用，并非按照物品的实际价值以及您的预期收益收取费用，本着公平合理的原则，您同意本协议约定的各项理赔规则；未保价物品在递送环节因我们的过错发生灭失、破损、短少的，公司将在运费的3倍范围内承担赔付责任（最高不超过200元），若您认为该赔偿标准不足以弥补您的损失，您应当根据物品的实际价值进行保价，具体的保价规定请您参阅《物品保价服务协议》；若您未选择保价递送，则视为物品价值不超过500元。庭审中舒某认为该条款系格式条款，应认定为无效，而某运输公司认为舒某在注册时同意《物品保价服务协议》的行为，即已同意接受保价条款的约束。

另庭审中双方对于物品的实际价值存在争议，舒某向法庭提交了购买项链组成物的支付凭证，某运输公司并未认可。

【案件焦点】

1. 案涉保价条款是否系格式条款及其效力问题；2. 当事人签署用户协议是否系对保价条款的认可；3. 若保价条款无效，被告应如何承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：舒某作为托运人下单并支付费用，某运输公司作为承运人应当按照托运人指令将物品安全递送至指定地点，但是某运输公司员工将物品丢失应当承担违约责任，赔偿托运人遭受的损失。某运输公司抗辩称舒某在注册某运输公司应用程序时点击确认《服务用户协议》，系认可协议内容的行为，故应当受该协议中保价条款的约束，在舒某并未支付保费的情形下，某运输公司仅需在运费3倍范围内承担赔偿责任。但是经审查，该协议内容系某运输公司单方面制作，对于免除或限制责任的条款未以字体加粗等形式进行标识，未能起到提示、说明的义务，且明显不合理地减轻了承运人某运输公司的责任，加重了舒某作为托运人的义务，故根据《中华人民共和国民法典》第四百九十六条、第四百九十七条之规定，《服务用户协议》中的

保价条款符合格式条款的构成要件应当认定为无效，对双方当事人并不具有法律约束力。

关于寄送物品价值的认定，因舒某向法庭提交了网上购买绿松石项链、项坠的微信聊天记录以及付款的支付凭证，故法庭对于舒某可以明确的损失部分予以支持。

综上，北京市海淀区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第四百九十六条、第四百九十七条第二项、第五百零九条、第五百七十七条、第五百八十四条、第八百零九条、第八百一十一条、第八百三十二条之规定，判决如下：

一、被告某运输公司与原告舒某签署的《服务用户协议》第六条第三款无效；

二、被告某运输公司向原告舒某偿还损失3.6万元；

三、驳回舒某的其他诉讼请求。

某运输公司不服一审判决，提起上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：争议焦点在于《服务用户协议》第六条第三款是否系格式条款及其效力。格式条款的提供方对免除自己责任的条款应当尽到提示说明义务，否则该条款不成为合同内容。《服务用户协议》中限制赔偿的相关条款，明显减轻了某运输公司在合同中的主要责任，且未能以足够充分的方式对用户进行提示说明，故该条款不具有约束力，应属无效。且舒某提供了相关证据对丢失物品的价值予以证明，故某运输公司应当照价赔偿。

综上，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的发生有其偶然性也有其必然性。随着移动支付技术、电子商务技术的不断发展，快递已然成为人们生活中不可或缺的一环。海量的快递构成了庞大的基数，即使概率再低，消费者也会遭遇快递毁损、丢失的情形，而快递公

司为了降低交易成本，降低规避经营风险，通常会在快递服务合同中约定保价条款。①实践中，寄送人与物流公司就保价条款的性质与效力有着截然不同的观点，保价条款是否系格式条款及其效力问题往往成为案件的争议焦点。

因缺乏意思表示一致的协商过程，提供格式条款的一方形成了“法律或事实上的垄断”，所以我国立法例对于格式条款的态度始终较为严苛。但是格式条款在实现节省交易成本，实现交易标准化、规模化方面具有不可替代性，是现代市场交易中不可或缺的一项重要法律制度。所以，只能对格式条款进行规范和控制，扬长避短，以完善格式条款法律制度的方式来严控格式条款的负面效应。

根据《中华人民共和国民法典》第四百九十六条之规定，合同条款符合具备如下三要素即可认定为格式条款：为了重复使用、预先拟定、未与对方协商。其中，“未与对方协商”是认定格式条款的关键，也正是格式条款受到法律否定性评价的原因。物流公司所提供的合同条款确系为了重复使用而预先拟定，同时寄送人若需使用物流公司的服务，其只能接受物流公司所提供的合同条款，并无任何协商讨论修改的余地，故案涉合同条款系格式条款几乎已成定论。

但是合同条款系格式条款并不意味着必然系无效条款，随着《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》的出台，关于格式条款效力的认定路径得到进一步的完善，即格式条款分为“绝对无效情形”与“相对无效情形”。绝对无效情形包括：具有民事法律行为无效的情形，属于法定无效的免责条款情形；利己损彼达到不合理程度；排除相对方的主要权利。相对无效情形包括：免除或减轻合同提供方责任、排除或限制对方权利(未达到不合理程度)等与对方有重大利害关系的异常条款，经格式条款提供方依法履行了提示和说明义务之后，该条

款有效。本案中，某运输公司主张的保价条款既免除了某运输公司所应承担的数万元赔偿明显达到不合理程度，

①通过对我国十家大型物流公司《快递服务协议》《电子运单契约条款》梳理，所有快递公司均约定了保价条款，未保价的赔付规则为，按照实际价值赔偿损失，但是最高赔付金额为3倍至10倍运费金额，部分公司还约定了理赔期限与发生纠纷后管辖。

也未尽到提示说明义务，故案涉条款无效。但是目前物流公司所提供的保价条款大多均以标红、加粗、下划线的形式进行了提示，保价条款也称为下单界面中提醒的主要内容。此时法院审查的焦点即应集中于免除或减轻合同提供方责任是否系不合理程度，实践中应结合损失金额与赔偿金额进行总体判断，不应一概认定为无效。

格式条款之于商业活动而言，无疑是“双刃剑”，现代化的市场交易无法脱离格式条款的参与，但同时也应时刻保持对格式条款的警惕，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》无疑是对格式条款制度的细化与完善，不仅强化了对格式条款效力的控制，同时也实现了合同提供方与接收方之间利益的衡平。

编写人：北京市海淀区人民法院 武文昊

乘客无权直接请求网约车司机等履行辅助人承担违约责任

——李某诉某汽车租赁公司公路旅客运输合同纠纷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第一中级人民法院(2023)渝01民终9863号民事判决书

2. 案由：公路旅客运输合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：李某

被告(上诉人)：某汽车租赁公司

【基本案情】

2021年10月17日11时许，李某通过网约车平台某科技公司，搭乘吕某驾驶的小型轿车在行驶过程中与其他车辆发生碰撞，导致李某受伤。案涉事故发生时，李某落座于车辆后排，未系安全带。该事故经重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队认定，案涉车辆驾驶人吕某应承担事故的全部责任。

案涉车辆登记于某汽车租赁公司名下。李某遂以某汽车租赁公司作为承运人违反公路旅客运输合同为由，起诉请求某汽车租赁公司支付医疗费、伤残赔偿金、误工费等各项赔偿款共计723916.56元。

【案件焦点】

乘客搭乘网约车发生交通事故遭受损害，选择以公路旅客运输合同作为请求权基础主张违约责任，责任主体应当如何认定。

【法院裁判要旨】

重庆自由贸易试验区人民法院经审理认为：某汽车租赁公司系案涉车辆的登记所有人，对外有公示效力。案涉车辆从事网约车运营，李某通过网约车平台与某汽车租赁公司建立的运输合同关系合法有效，某汽车租赁公司是合同相对人，承担承运人义务，受运输合同约束。某汽车租赁公司与吕某之间签订的挂靠合同不得对抗第三人。根据《中华人民共和国民法典》第八百二十三条之规定，李某乘坐某汽车租赁公司运营的车辆导致受伤，某汽车租赁公司应对李某的损害结果承担全部责任。李某乘坐机动车未按规定系安全带的行为违反道路交通规章制度，存在过失，应酌情减轻某汽车租赁公司应负的赔偿责任。根据双方过错程度，一审法院认定李某承担15%的责任，某汽车租赁公司承担85%的责任。

重庆自由贸易试验区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第八百零九条、第八百二十三条、第一千一百七十九条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第八条第一款、第九条、第十条第一款、第十一条、第十二条第一款、第十三条、第二十二条第二款以及

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十五条之规定，判决如下：

- 一、某汽车租赁公司在判决生效后十日内向李某支付赔偿金333403.56元；
- 二、驳回李某的其他诉讼请求。

李某、某汽车租赁公司均不服一审判决，提起上诉。

重庆市第一中级人民法院经审理认为：李某在案涉交通事故中遭受损害，本案中选择以公路旅客运输合同作为请求权基础，请求某汽车租赁公司承担违约责任。而认定某汽车租赁公司是否应当承担责任的前提，在于认定某汽车租赁公司与李某之间是否成立公路旅客运输合同关系。本案中，李某系通过网约车平台某科技公司搭乘案涉车辆。《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十六条规定，网约车平台公司承担承运人责任，应当保证运营安全，保障乘客合法权益。根据前述规定，与李某订立公路旅客运输合同关系的相对方即承运人应当是网约车平台某科技公司，并非某汽车租赁公司。某汽车租赁公司仅系承运人的履行辅助人。因此，李某主张公路旅客运输合同以外的第三方某汽车租赁公司承担承运人责任，没有事实和法律依据。

重庆市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第八百二十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销重庆自由贸易试验区人民法院(2022)渝8601民初307号民事判决；
- 二、驳回李某的全部诉讼请求。

【法官后语】

随着互联网技术与共享经济日益紧密融合发展，网约车逐渐成为人们出行选择的重要交通工具，但是当乘客搭乘网约车发生交通事故时，却时常发生网约车司机、车辆被挂靠公司、网约车平台等多个主体相互推诿责任的情况，导致遭受损害的乘客权益难以得到保障。司法实践中，网约车发生交通事故造成乘客损害，因侵权责任与合同责任发生竞合，乘客大多选择提起侵权责任诉讼，对此的裁判规则已较成熟明晰，大多数生效判决均认定网约车平台应当基于安

全保障义务承担相应的承运人责任。然而，当乘客选择提起合同责任诉讼时，即对于本案所涉及的违反公路旅客运输合同约定的责任主体认定问题，各地法院的认识存在一定的分歧，有的生效判决认定网约车驾驶人作为承运人承担赔偿责任，有的生效判决认定车辆被挂靠的运输公司作为承运人承担赔偿责任，还有的生效判决认定车辆驾驶人与被挂靠运输公司承担连带赔偿责任。因此，厘清公路旅客运输合同的主体关系，是本案值得探讨的问题。

《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十六条规定，网约车平台公司承担承运人责任，应当保证运营安全，保障乘客合法权益。该部门规章基于合同特征、公共安全等多方面因素考虑，认定网约车平台承担承运人责任，即网约车平台作为公路旅客运输合同的主体承担责任，具有重要的参照适用意义。

第一，从合同的规则设置来看，网约车平台系格式合同等规则的单方制定者。网约车平台在其研发的打车软件中事先设置了包括计价标准、派车原则、违约责任等合同条款及相关规则，而其他主体无论乘客、司机还是其他运输主体，均没有改变相关规则的权利和能力。

第二，从合同的订立过程来看，网约车平台处于合同直接订立者的地位。乘客通过网约车平台打车，意在与网约车平台之间订立运输合同，并没有选择特定司机或其他运输主体的主观意图，乘客下单时也不能确定为其提供运输服务的车辆信息及司机身份，而网约车平台在派单时却享有选择司机等权利。

第三，从合同的履行特征来看，网约车平台扮演着组织管理者的主动角色。虽然网约车平台并未直接履行合同，但其对履行过程全程进行组织安排、监督管理甚至调度控制，网约车司机仅系接受网约车平台指派以其名义履行合同义务的履行辅助人，如在原本指派的司机无法履行运输义务时，网约车平台有权调配其他司机提供运输服务。

第四，从合同的利益分配来看，网约车平台享有绝对的支配性权利。网约车平台不仅可以直接获取合同收益，而且对于计费标准、收费方式、收益分配比例等与收益相关的重大事项均享有充分的话语权和决定性的支配权限。

因此，与乘客之间成立运输服务法律关系的合同主体系网约车平台，基于合同的相对性原则，乘客主张承担违约责任的主体也只能是网约车平台，而并非辅助网约车平台履行合同义务的网约车司机或其他运输主体，即使车辆被司机挂靠登记于第三人名下，对于乘客而言，该第三人的身份亦仅系网约车平台公司的驾驶辅助人，故乘客无权直接请求作为履行辅助人的网约车司机或其他运输主体承担违约责任。

编写人：重庆市第一中级人民法院 付永雄 李逾婧

十五、委托合同纠纷

32

代运营商单方删除商品推广链接的行为性质及其法律后果

—— 某食品公司诉某电子商务公司委托合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2022)渝05民终6501号民事判决书

2. 案由：委托合同纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、上诉人):某食品公司

被告(反诉原告、上诉人):某电子商务公司

【基本案情】

某食品公司是在某网购平台从事速食食品销售的商家。2020年3月30日,某食品公司与某电子商务公司签订《代运营服务合作协议》,约定某食品公司委托和授权某电子商务公司进行运营服务,主要包括店铺设计与装修、营销推广、产品销售等,合同期限自2020年4月1日0时起至2021年3月31日24时止。2021年3月4日,某食品公司向某电子商务公司发出《告知函》,告知某电子商务公司合同到期后,不再续签合同,并将于2021年4月1日0点收回某

网购平台“官方旗舰店”的运营管理权限。2021年3月31日10点左右，某电子商务公司删除3个商品ID的推广链接，该三个推广链接对应的商品销量在某食品公司店铺内排名分别为第1名、第3名、第6名，2021年3月，该三款商品占该店铺总销售额的48.64%，剩下的24款产品销量占比51.36%。2021年3月31日12点50分，某食品公司登录运营账号，对账号的登录密码进行了修改。链接删除之后，某食品公司未按时向某电子商务公司支付剩余推广费用80763.1元。某食品公司起诉请求某电子商务公司支付违约损害赔偿金76485.68元，某电子商务公司反诉某食品公司支付逾期付款滞纳金46842.6元及违约金263275.7元。

【案件焦点】

1. 某电子商务公司删除商品推广链接行为是否构成违约行为；2. 某食品公司是否可以行使先履行抗辩权。

【法院裁判要旨】

重庆市南岸区人民法院经审理认为：某电子商务公司删除某食品公司旗舰店三款商品的推广链接，一定程度上影响了该商品在某网购平台的搜索排名，也对某食品公司销售该商品造成了影响。某食品公司为提升该商品在某网购平台的曝光度，必然产生一定的推广费用支出。综合考虑合同的履行情况、某电子商务公司的过错程度等因素，一审法院酌情确定某电子商务公司赔偿某食品公司2万元。

重庆市南岸区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民法典》第五百零二条第一款、第五百零九条第一款及第二款、第五百七十七条、第五百八十三条、第五百八十四条、第五百八十五条、第九百一十九条、第九百二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、由本诉被告某电子商务公司于本判决生效之日起十日内支付本诉原告某食品公司违约损害赔偿金2万元；

二、由反诉被告某食品公司于本判决生效之日起十日内支付反诉原告某电子商务公司逾期付款违约金(以60763.1元为基数,自2021年4月19日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准计算至2021年8月13日止);

三、驳回本诉原告某食品公司的其他诉讼请求;

四、驳回反诉原告某电子商务公司的其他诉讼请求。

双方均不服一审判决,提起上诉。

重庆市第五中级人民法院经审理认为:推广链接虽非商品链接,但因在网络购物平台上的推广行为能促进产品销售并为店铺带来浏览量,客观上会起到引流的作用进而提高店铺销量,具有一定的财产属性。某电子商务公司虽拥有独立的运营权限,但其作为接受委托的服务提供方,应当遵循诚实信用原则并以某食品公司的利益最大化为标准履行合同,不应刻意减损已经形成的产品竞争优势。某电子商务公司无合理理由在合同到期的最后一天删除推广链接的行为违反诚实信用原则,应当认定为违约并承担相应的违约责任,一审法院酌情确定案涉违约损害赔偿金为2万元并无不当,故维持该项判决。某食品公司为预防某电子商务公司进一步损害其利益,通过修改密码的方式阻止某电子商务公司登录运营账号系为防止损失扩大、维护其正当权益的合理行为,不应认定为违约。某食品公司逾期支付剩余推广费的金额并未超过某电子商务公司违约给某食品公司造成的损失范围,亦是合理行使其先履行抗辩权。

重庆市第五中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条第一款、第五百二十六条、第五百七十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项等规定,判决如下:

一、某电子商务公司支付某食品公司违约损害赔偿金2万元;

二、驳回某食品公司的其他诉讼请求;

三、驳回某电子商务公司的诉讼请求。

【法官后语】

随着互联网产业的蓬勃发展,电商平台已成为日常生活中不可或缺的购销

渠道，潜移默化地改变着人们的消费习惯、商家经营模式。除互联网平台自营业务外，代运营业务已经成为电子商务产业重要的组成部分。本案属于电商代运营领域的典型纠纷情形，通过识别商品推广链接价值属性，明晰代运营合同双方当事人权利与义务界限，为此后审理类似案件提供有益的参考价值。

一、财产属性：商品推广链接具有直接的经济价值

商品推广链接也被称为佣金链接或定向链接，是电商平台(或代运营商)提供给商家的一种营销工具，通过这些链接可将潜在消费者引导到指定的商品或店铺页面，从而达到引流效果、促成交易。当消费者通过链接完成交易时，商家可获得直接的经济利益，实现营业创收；电商平台(或代运营商)也可以获得一定比例的佣金。商品推广链接因此也就具有了财产属性，是提升销售转化率、增加营业利润的重要工具。

二、行为评价：代运营商单方删除推广链接的法律性质

电商代运营模式主要指商家向代运营商支付服务费，代运营商提供网店装修、营销推广、产品销售等代运营项目服务。代运营商单方删除委托方推广链接的法律性质，可从以下两个方面进行分析。

首先，代运营商删除商品推广链接是否构成违约，需根据双方签订的合同内容来认定，属当事人意思自治。案涉《代运营服务合作协议》对某电子商务公司如何运营无明确约定，其可独立运营不受某食品公司的干涉。因此，在一般情形下，若合同无禁止性约定，代运营商单方为正常运营删除商品推广链接可视为独立经营行为，不构成违约。

其次，电商付费委托代运营商进行链接推广和产品销售，主要目的是增加盈利、完成销售目标。推广链接仅是代运营商实现盈利的手段，其单方删除推广链接是否违约，应当放在是否符合盈利、引流的目的来看，以此评价合同履行行为是否妥当。某电子商务公司作为受托运营方，在合同到期的最后一天删除某食品公司几款爆款商品的商品链接，没有尽到合同全面履行义务，违反了诚信原则。该行为已超出独立经营范围，存在明显不当，已构成违约。

三、行为后果：代运营商不当删除推广链接的法律后果

第一，根据《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定，代运营商不当删除推广链接给合同相对方造成损失的，应承担违约损失赔偿责任。某食品公司损失主要指履行利益损害，即某食品公司在合同履行后原本可获得的利益，现因某电子商务公司的不当删除推广链接行为而无法获得，某电子商务公司应当对此承担赔偿责任。

第二，根据《中华人民共和国民法典》第五百二十六条的规定，当事人互负债务，有先后履行顺序……先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。某食品公司与某电子商务公司因代运营合同互负债务，合同履行期限均已届满，按约定某电子商务公司履行代运营义务在先，其后，某食品公司才支付佣金。现因某电子商务公司不当删除推广链接行为不符合约定，给某食品公司造成了损失。故某食品公司在某电子商务公司赔偿损失前，主张行使先行履行抗辩权，具有法律依据和事实根据。

编写人：重庆市第五中级人民法院 邓筱茜 王晓宇

无偿委托合同关系的风险分担及责任承担的法律适用

——赵某诉赖某委托合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民终3977号民事判决书

2. 案由：委托合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):赵某

被告(上诉人):赖某

【基本案情】

赵某与赖某原系朋友关系,双方于微信聊天的过程中,因赖某称在与朋友做自营基金项目,保证高额收益,赵某先后于2020年11月12日、2021年2月19日出资30万元、90万元共计120万元,委托赖某投资理财。在双方微信聊天中,赖某宣称是“自己的自营团队在操作”,“我至少能确保安全,收益不会让你失望”“你到时候跟着我买就可以”“我们自己做的东西最起码安全”“我们三年上百亿规模”“目前基金收益率达56%,按这个速度,个人一年可以得到四倍的回报”。

赖某(基金份额持有人)与科技公司(基金管理人)分别签订了两份《自营基金认购协议》。第一份《自营基金认购协议》签订时间为2020年11月16日,认购金额为280万元,约定基金存续期限为1年,自2020年11月16日起至2021年11月15日止。第二份《自营基金认购协议》签订时间为2021年2月22日,认购金额为1365万元,约定基金存续期限为1年,自2021年2月22日起至2022年2月21日止。赖某在庭审中自述,前述资金均是其替不同人员代持,其中赵某投资金额为120万元。

2022年3月7日,赖某通过微信告知赵某他们遇到了骗子,以前每个月公布的业绩应该都是假的,赖某会去报警。3月8日,赵某要求赖某将交易记录及合同提供给赵某。赖某表示他亦是受害者,对于代持损失会给个交代。

2022年3月10日,赖某与朱某等前往深圳市公安局南山分局经济犯罪侦查大队报案。赖某自述:“我与犯罪嫌疑人梁某、李某认识是由以前银行的同事邹某介绍的,时间是2020年6月前后,邹某介绍梁某、李某股票交易很厉害、收益高,我经过初步交流了解,认可他的交易逻辑,所以于2020年11月投入280万元给他做股票。2021年春节前分得收益大概50%不等。2021年2月又投入1365万元……合同到期后至今无法兑付,打他们电话不接,信息不回,

处于失联状态……所以特来报案……”

2022年4月22日，赵某向法院提起本案诉讼。

2022年5月6日，深圳市公安局南山分局出具一份立案告知书，上载：朱某被合同诈骗一案，我局认为符合立案条件，现已立案侦查。

赵某另提出如下诉讼请求：(1)赖某赔偿赵某投资理财损失120万元，并自起诉之日起按年息6%计算利息，利随本清。(2)本案诉讼费用由赖某承担。

赖某辩称：赵某委托赖某为其代购基金，赖某未收取任何报酬，应属于无偿的委托合同，其也是受害者，故赵某应自行承担投资理财损失。

【案件焦点】

1. 赖某在受托过程中是否存在故意或重大过失；2. 本案损失及双方的责任应如何认定。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市湖里区人民法院经审理认为：关于争议焦点一，赖某在受托过程中存在重大过失。理由如下：本案中，赵某与赖某系好友关系，以表兄妹相称，赖某曾担任银行行长，案涉的私募基金投资系双方聊天过程中赖某向赵某推荐的。私募基金投资属于高风险的投资产品，赖某相较于赵某有更为丰富的金融经验，其在向赵某推荐产品时，理应对投资风险有合理的注意和提醒义务。但其并未将该投资基金基本情况、基金行业协会登记手续办理进程、基金管理人情况等基本信息告知赵某，反而宣称是“自己的自营团队在操作”，强调“我至少能确保安全，收益不会让你失望”“你到时候跟着我买就可以”“我们自己做的东西最起码安全”“我们三年上百亿规模”等。基于双方的信赖关系，赖某该种陈述会对委托人的判断产生重大影响。同时，根据赖某自己提交的报案自述材料可以看出，赖某受托处理的资金达到1645万元，在处理如此大额投资资金的情况下，其并未对科技公司及其所谓自营基金做过尽职调查，也未主动向委托人进行过相应的披露，可见，其未尽到合理的注意义务和风险提示义务，存在重大过失。

关于争议焦点二，法院经审理认为，虽然赖某在处理委托事务过程中存在重大过失，但赵某作为完全民事行为能力人，对涉案私募投资基金存在高回报收益的同时亦可能存在高风险未予重视，不仅未签订书面委托合同明确委托事项，对于赖某的具体投资内容亦不过问，其对于损失的产生亦存在一定过错。综合考量双方的过错程度和对损失发生的原因力大小，再结合本案无偿接受委托的情况，酌情认定赖某赔偿赵某60万元。关于赵某要求赖某支付自起诉之日起按年息6%计算利息的诉求，因本案案涉法律关系为委托合同，并非借贷关系，故该诉求并无事实和法律依据，法院不予支持。

福建省厦门市湖里区人民法院依照《中华人民共和国民法典》等规定，判决如下：

- 一、赖某于本判决生效之日起十日内向原告赵某赔偿损失60万元；
- 二、驳回原告赵某的其他诉讼请求。

赵某、赖某均不服一审判决，提起上诉。

福建省厦门市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

所谓“受人之托，忠人之事”，委托合同具有较强的人身依赖性。在无偿委托合同中，因委托人单方面获益而受托人未获报酬，故受托人只有在故意或者重大过失造成委托人损失时，才负有赔偿责任。本案的关键在于，以委托投资为内容的无偿委托合同，应如何认定受托人是否存在过错？对于投资损失的责任应如何承担？

首先，关于受托人过错的判断。所谓故意，是指受托人明知或者应当知道损害可能发生，却促使或者放纵该损害的发生。所谓重大过失，是指受托人在其注意义务范围内，能够预见而没有预见，或者已经预见但轻信可以避免从而导致损害的发生。具体到委托投资行为当中，对于私募基金等高风险的权益类

投资，受托人在推荐产品时应对投资风险有合理的注意和提醒义务。在本案中，无偿受托人以自身专业背景为背书，采取夸大、虚假性的描述导致委托人投资决策失误并造成损失，构成重大过失，应当向委托人承担赔偿责任。

其次，关于责任的承担。由于投资理财本身存在较高的风险，委托人对于自身的投资行为也应当保持审慎态度，对投资情况进行监督和管理。

《中华人民共和国民法典》第九百二十七条规定，受托人处理委托事务取得的财产，应当转交给委托人。根据权利义务相一致原则，当受托人基于委托事务而取得积极性财产时，该财产利益归属于委托人，与此同时，当委托人因此取得消极性财产(如亏损、负债)时，该消极性后果亦应当由委托人承担。凡是投资均自带风险，这是由商业属性所决定的。若委托人未尽到合理的注意义务，单纯依赖受托人的决策而未采取任何风险防范措施，其自身也对投资失败的风险承担一定的责任。

综上，无偿委托并不免除受托人的基本注意义务，特别是在投资领域，受托人应当秉持诚信和专业的原则，向委托人充分披露信息并提示风险。同时委托人也应意识到投资行为的风险性，审慎考察受托人的专业能力、信誉及投资经验，积极参与委托事项的监督和管理。本案通过对无偿委托投资行为的分析，对于明确无偿委托合同关系中受托人的责任边界、双方的风险分担及权利义务平衡标准具有借鉴意义。

编写人：福建省厦门市湖里区人民法院 薛潇 郭雅莹

十六、委托理财合同纠纷

34

民间委托理财合同中事前保底条款与事后亏损 负担承诺的效力认定及损失分担

—— 于某诉杨某委托理财合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省洛阳市中级人民法院(2023)豫03民终4248号民事判决书

2. 案由：委托理财合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 于某

被告(被上诉人): 杨某

【基本案情】

于某、杨某二人系同社区居民、朋友关系。2022年12月30日于某与杨某口头协商一致后,于某将自己的股票账户及交易密码交付给杨某,由杨某代为进行股票操作、交易,当日于某账户余额为718.68元,股票市值392915元,总资产393633.68元。2023年1月6日,杨某向于某发送微信,载明“凡是经我操作造成的损失,我全部承担,但是利润必须按3:7的比例分配,我得7,

你得3,我接手时,你账上的钱是383000元”,于某表示同意。截至1月20日,于某账户余额为580.03元,股票市值329777元,总资产330357.03元。当天,杨某向于某出具《欠条》一份,载明:“今欠到于某人民币53000元(因股票操作失误给其造成的这个损失皆由我承担,2023年3月20日前,股票若不能补回这个损失,本人须现金付清此款)。”2023年3月20日,于某账户余额为808.63元,股票市值279134元,总资产279942.63元。2023年3月20日股市收盘后,于某将上述股票的交易密码进行了变更,并告知杨某终止委托。

于某提出如下诉讼请求:(1)杨某赔偿于某损失款113691.05元及利息(以113691.05元为基数,自2022年12月30日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至全部履行完毕之日止)。(2)诉讼费由杨某承担。

【案件焦点】

案涉事前保底条款是否有效,杨某是否应赔偿于某损失款113691.05元及利息。

【法院裁判要旨】

河南省洛阳市孟津区人民法院经审理认为:于某将自己的证券账户委托给杨某管理、投资,双方约定盈利分成,杨某以个人名义接受委托,故于某与杨某之间形成民间委托理财合同法律关系。关于杨某接受委托后给于某方造成的损失问题,本院认为2023年1月20日杨某自愿向于某出具欠条,并明确载明其因炒股造成于某损失,欠于某53000元,法院认为该欠条意思表示明确,且与杨某向于某发送的微信信息载明的内容相互印证,予以采信。故于某主张杨某支付赔偿款53000元的诉讼请求证据充分,予以支持;关于2023年1月20日之后至2023年3月20日杨某因炒股行为给于某造成的损失问题,孟津法院认为2023年3月20日股市收盘前于某和杨某并未将账户上股票全部卖出变现,于某账户上的股票市值不能作为判断其实际损失的唯一客观依据,双方在2023年3月20日亦未对股票账户资产进行结算,即2023年1月20日之后至3月20

日于某因股票交易造成的实际损失不能客观确定，故于某仅依据2023年3月20日收盘时的股票市值对应的资产数额来主张其损失的诉讼请求证据不足，不予支持。杨某辩称的于某单方终止委托违反双方约定，其不承担赔偿责任的抗辩主张证据不足、理由不充分，不予支持。

河南省洛阳市孟津区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第九百二十九条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十五条之规定，判决如下：

一、杨某于本判决生效后十日内向于某支付赔偿款53000元；

二、驳回于某的其他诉讼请求。

于某不服一审判决，提起上诉。

河南省洛阳市中级人民法院经审理认为：本案系民间委托理财合同纠纷。本案争议焦点为于某股票账户出现的损失如何确定及相应损失如何分担的问题。

一、关于损失的分担问题

本案中，于某将股票账户交付于杨某操作，双方事先约定了盈利亏损的分配方案，即盈利于某与杨某按3:7分配收益，亏损则由杨某全部承担。上述关于损失全部由杨某承担的约定属于事先约定的保底条款，该约定免除了委托人应承担的投资风险，诱导作为委托人的投资者误判或漠视投资风险，非理性地将资金投入金融市场，违背了委托代理的基本原理，亦扰乱了金融市场投资的交易规则。该事前保底条款约定应属无效，根据法律规定，合同无效后行为人因该行为取得的财产应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。本案中，因案涉股票账户内的资产并未发生所有权转移，杨某亦未从中取得任何财产，因此不涉及返还事宜。但根据案涉股票账户的资产净值变化过程，应当认定于某因案涉委托理财合同的履行遭受了损失，对出现的亏损则应根据双方的过错予以分担。

关于2023年1月20日《欠条》的效力，杨某操作股票出现亏损后自愿向于某出具《欠条》承诺之前产生的炒股损失53000元由杨某承担，该《欠条》

明确了既已发生的炒股损失及该损失的负担问题，属于对事后亏损负担约定，该约定确定的权利义务只会对协议双方构成实质性影响，不会如事前保底条款一样诱导投资者误判或漠视投资风险，亦不会引发损害社会公共利益后果，因此该事后亏损负担约定即案涉《欠条》应当认定有效。

本案委托理财期间自2022年12月30日起至2023年3月20日止，其间，既存在事前保底条款约定又存在事后亏损负担约定，通过上述分析，双方关于事先约定损失全部由杨某承担的约定无效，但出现亏损后杨某出具的《欠条》应认定有效，故2022年12月30日至2023年1月20日的损失，应由杨某按照其出具的《欠条》内容承担相应责任。关于2023年1月20日至3月20日产生的理财损失，因双方事前关于收益分配、损失承担的约定不再具有法律约束力，且杨某未对此期间损失作出承诺，则该期间的损失承担依法应当根据双方的过错程度确定责任比例。于某、杨某均为完全民事行为能力人，对股票市场存在风险应当有足够的认知，无论是将股票账户交予他人操作，还是代为操作他人股票账户，双方均具有一定的过错，结合双方约定的盈利分配比例为3:7，故法院酌定该期间的损失亦按照于某30%、杨某70%的比例承担。

二、关于本案委托期间的理财损失如何确定的问题

双方在确定委托理财合同关系时未约定理财盈利亏损的计算方法，现于某主张按照股票账户总资产自委托起始日至委托届满日期期间的实际差额来计算损失，但杨某对此不予认可，且按照于某主张的计算方法亦不能得出《欠条》载明的53000元数额，在于某不能提供其他证据证明双方曾就其主张的计算损失方法达成过一致合意的情况下，基于股票交易的特殊性，应以实际损失计算亏损数额。截至2023年3月20日，于某账户内尚有单支股票未卖出变现，双方亦未能及时清算导致实际损失难以确定，但杨某一审中自认2022年12月30日至2023年3月20日经其手操作买入、卖出股票亏损为95949元（不含某食品股票），故法院据此认定杨某经手操作股票期间于某股票账户总损失数额为95949元。因杨某向于某出具《欠条》自认截至2023年1月20日的损失为53000元，则2023年1月20日至2023年3月20日的损失经计算为42949元

(95949-53000=42949元),根据前述认定的责任比例,该期间杨某应承担的损失数额为 $42949 \times 70\% = 30064.3$ 元。综上,杨某应承担的损失数额应为上述两部分之和,即本案杨某应向于某支付损失赔偿款共计为83064.3元(53000+30064.3=83064.3元)。

河南省洛阳市中级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定,判决如下:

一、撤销河南省洛阳市孟津区人民法院(2023)豫0308民初2245号民事判决第二项;

二、变更河南省洛阳市孟津区人民法院(2023)豫0308民初2245号民事判决第一项为:杨某于本判决生效后十日内向于某支付赔偿款83064.3元;

三、驳回于某的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案的典型性在于,委托理财期间自2022年12月30日起至2023年3月20日止,委托期间当事人双方既存在事前保底条款约定,也存在2023年1月20日在理财亏损出现后杨某自愿向于某出具的《欠条》,也即事后亏损负担承诺。而对事前保底条款和事后亏损负担承诺效力的区分,既是对契约正义和契约自由的平衡,根据法律行为对公序良俗的影响程度,合理把握司法公权介入意思自治的限度;同时也是对维护金融市场秩序需要和保护广大投资者利益需要的平衡,既要引导投资者理性判断投资风险,也要在个案中保护投资者的合法权益,保障金融市场稳定有序运行。

一方面,事后亏损负担承诺确认有效。其理由主要在于:(1)从风险分配角度来讲,事后亏损负担承诺是受托人在充分了解现存风险的情况下积极与委托人达成的合意。(2)从投资者决策角度来讲,事后亏损负担承诺对投资者决策的诱导力度较小,符合公平原则与公序良俗。(3)从金融市场秩序角度来讲,事后亏损负担承诺对遏制金融市场投机行为、稳定金融市场秩序、防范化解金融风险有一定的积极作用。(4)从广大投资者利益角度来讲,事后亏损承诺是受托人进行的风险自认,有利于维护投资者利益。就本案而言,受托人杨

某操作股票出现亏损后自愿向委托人于某出具《欠条》,承诺之前产生的炒股损失53000元由其承担,该《欠条》明确了既已发生的炒股损失及该损失的负担问题,该约定确定的权利义务只会对协议双方构成实质性影响,不会如事前保底条款一样诱导投资者误判或漠视投资风险,亦不会引发损害社会公共利益的后果,因此该事后亏损负担约定有效,也即案涉《欠条》应当认定有效。

另一方面,事前保底条款的效力存在不同观点。一种实务观点认为,保底条款无效,金融市场的基本交易规则就在于风险自担,而保底条款则突破了这一基本交易规则,违背了金融市场基本规律。另一种实务观点认为,保底条款有效,公权不应随意干涉市场主体的自由意志选择。还有一种观点认为,保底条款可撤销,若当事人以保底条款明显违反公平原则申请撤销,法院应当予以支持。笔者认为,事前保底条款应为无效,其主要具有两个方面的理由。

其一,关于认定事前保底条款无效的法律依据,有学者认为,将事前保底条款有效或无效的社会结果加以预测后,着重于社会效果预测和社会目的衡量,以社会效果更符合社会目的为目标,认定事前保底条款无效的法律推理路径在于对《中华人民共和国民法典》第六条和第一百五十三条的填补,也即事前保底条款因违反公平原则和违背公序良俗而无效。

其二,关于认定事前保底条款无效的推理路径:一是认定事前保底条款无效可以弥补行政监管的不足。非金融机构或自然人接受不特定多数人委托理财数额累积到一定程度后,已明显带有非法集资的性质,极易产生社会负外部性效应,因此法院有必要以司法干预抵销其负外部性,弥补行政监管的不足。二是认定事前保底条款无效可以有效引导社会投资风向。司法裁判理应实现法律效果和社会效果的统一,在实现法律效果的前提下,还应关注法律规则背后的价值因素、道义性需求和社会价值观,我们有必要通过利益衡量、漏洞填补的方式确认事前保底条款无效,保证法律的正确适用和案件的妥当裁判。三是认定事前保底条款无效符合委托代理责任承担规则。民间委托理财的风险应由委托人自行承担,但事前保底条款却约定由受托人承担全部风险,这显然违背了委托代理关系中的责任承担规则,应属无效。四是认定事前保底条款无效遵循

了自负盈亏、等价有偿的金融原则。2018年出台的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》指出要打破“刚性兑付”,确立金融市场“卖者尽责、买者自负”的原则,而事前保底条款往往约定委托人仅享有收益、不承担风险,这明显违背了风险自负原则,不符合商事投资活动的本质,理应认定其无效。

论及本案,认定事前保底条款无效后,定分止争的另一个关键在于委托理财资产损失的认定和分担规则。

关于委托期间理财损失的确定,法院应着重审查当事人双方在签订民间委托理财合同时是否对理财盈利亏损的计算方法有过明确约定。如果当事人双方有明确约定,按约定的计算方式认定委托期间的理财损失;如果当事人双方没有明确约定,且委托人、受托人双方在案件审理过程中不能提供其他证据证明双方曾就盈利亏损的计算方法达成一致合意的情况下,基于股票交易的特殊性,应以实际损失为限来计算亏损数额,即委托期间的理财损失为委托期限开始时委托人实际交付受托人金融资产的当日市值与委托期限结束时受托人向委托人交还金融资产控制权时的当日市值之差。需要注意的是,对委托期间理财损失的认定应以受托人实际接手、掌控、操作的股票价值为准。

关于保底条款无效后,受托方未作出事后亏损负担承诺的损失部分的分担规则,笔者认为法院应对损失分担综合考虑案件实际以及委托人和受托人的过错程度等因素进行自由裁量。

一是要看各自的过错程度。包括:(1)要看委托人、受托人各自对合同无效的过错程度,实践中,受托人对委托理财合同的订立起到主导作用,且其基于知识技术和从业经历的优势,在明知事前保底条款约定无效的情况下,仍向委托人作出承诺,其过错程度更大;同时委托人也未尽到审慎注意义务,轻信受托人承诺,盲目追求低风险高回报,亦存在一定过错。(2)要看委托人、受托人各自对委托资产损失的过错程度,人民法院应着重审查受托人在委托理财期间是否尽到了审慎注意义务,以理财行为和理财结果为参照判断标准,同时还要查明委托人在受托人操作不当导致资产损失的情况下是否采取了适当措施防止损失的进一步扩大。

二是要看盈利分配约定。以公平原则和利益风险相匹配原则为基础，民间委托理财资产损失的风险分担可以委托合同中当事人双方对盈利的分配约定为参考，并依据当事人双方各自的过错程度作出适当调整。

综上所述，本案是关于民间委托理财合同同时存在事前保底条款和事后亏损承诺情形下如何认定保底条款效力、如何划定损失分担的典型案例。一直以来，民间委托理财合同中保底条款的效力认定与损失分担都是理论界和实务界的热议话题，目前审判实践对这一问题裁判标准模糊、认定结果不一。本文通过区分事前保底条款与事后亏损负担承诺，从法律推理和事实推理两条路径认定事前保底条款无效，总结出以填补《中华人民共和国民法典》第六条和第一百五十三条为核心，以弥补行政监管不足、引导社会投资风向、遵守委托代理规则、遵循自负盈亏金融原则为支撑的价值衡量体系；并进一步在认定事前保底条款无效后，以各自过错程度、盈利分配约定为判断要素构建起损失分担规则，对提炼裁判规则、统一裁判尺度具有实践意义。

编写人：河南省洛阳市中级人民法院 王甜甜

十七、物业服务合同纠纷

35

公共管道堵塞返水导致楼下损失，物业公司未履行疏通义务的，应承担违约责任

——周某、朱某诉某物业公司物业服务合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终4919号民事判决书

2. 案由：物业服务合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):周某、朱某

被告(上诉人):某物业公司

【基本案情】

周某、朱某系小区16-101室业主。2021年4月15日，周某、朱某与某物业公司签订《前期物业服务协议》。合同第二条约定某物业公司对周某、朱某的上述房屋提供物业服务，约定物业管理服务内容包括：房屋共用部位的维护和管理、房屋共用设施设备(包括共用的上下水管道、落水管等)及其运行的维护和管理。合同第三条约定物业服务质量参照无锡市普通住宅物业服务等级

六级服务标准执行。同日，开发商向周某、朱某交付了房屋。

2021年11月，周某、朱某外卫因二楼以上住户使用的主排污管堵塞导致家中返水致其屋顶出现水渍，周某、朱某遂向某物业公司报修。某物业公司疏通后，可见有较小的水流不断流出来，故告知周某、朱某疏通完成。2021年12月初，案涉房屋再次因同一原因致房顶大面积漏水，周某、朱某报修后，某物业公司再次疏通并告知疏通完成。2021年12月中旬，案涉房屋第三次因同一原因屋顶大面积漏水。多次漏水致周某、朱某装修严重受损。经街道协调，某物业公司组织对案涉房屋外卫进行开挖，发现排污管转弯处存在一块混凝土混合物。

另查明，无锡市普通住宅物业服务等级六级服务标准载明：对于排水系统，某物业公司应当每月清扫一次以上排水明沟，每季对地下管井清理一次，每半年对地下管井彻底疏通一次。

【案件焦点】

公共管道堵塞反水导致楼下损失，某物业公司是否存在违约行为。

【法院裁判要旨】

江苏省无锡市锡山区人民法院经审理认为：首先，根据《前期物业服务协议》的约定，某物业公司应当按照无锡市普通住宅物业服务等级六级服务的标准向周某、朱某提供物业服务。根据无锡市普通住宅物业服务等级六级服务标准，某物业公司应当每季对地下管井清理一次，每半年对地下管井彻底疏通一次。根据双方提供的证据，开发商于2021年4月15日将案涉房屋交付给业主，同时业主与某物业公司建立物业服务合同关系，根据上述标准，某物业公司应当迟于2021年10月15日对地下管井进行彻底疏通一次，但某物业公司未能提供其对地下管井进行彻底疏通的证据。其次，就成本案房屋装修损失的外卫公共管道返水事件，周某、朱某于2021年11月20日即发现小面积的返水，并报告给某物业公司，某物业公司未能重视，仅以管道口中有清水流水作为疏通完成的标志。正因为某物业公司未能完全疏通管道，反而告知案涉管道已疏

通，从而导致案涉房屋外卫主管道于2021年12月7日及12月16日的大规模返水，进而导致了周某、朱某的房屋装修损失。综上，某物业公司未能完全履行物业服务协议约定的义务，存在违约行为，现周某、朱某要求其承担赔偿责任的诉讼请求，于法有据。

关于具体损失，法院结合案件查明事实予以处理。

江苏省无锡市锡山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、第九百三十七条、第九百四十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，判决如下：

一、某物业公司于判决生效后十日内给付周某、朱某102038.28元；

二、驳回周某、朱某的其他诉讼请求。

某物业公司不服一审判决，提起上诉。

江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

随着社会的发展，高层住宅越来越多地出现在人们的生活中。管道使用频率、使用时间以及不当使用等几种因素叠加，导致管道堵塞的现象时有发生，作为低楼层的住处苦不堪言。本案原告就是一楼房屋业主，而堵塞的管道系二楼及以上住户使用的公共管道，原告家中因管道堵塞导致二楼反水，进而导致其家中受损，原告作为受害人在主张其权利时存在请求权的竞合，即原告可以侵权之诉主张楼上住户、开发商以及某物业公司承担财产损害赔偿责任，亦可以作为物业服务合同的相对方主张某物业公司承担违约责任。然，提起侵权之诉，原告需找出具体侵权人，其举证难度非常高，而提起违约之诉，被告明确，故本案原告主张某物业公司承担违约责任。

关于违约责任的承担方式，《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担

继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”本案中，原告主张了赔偿损失的违约责任承担方式。至于某物业公司应否承担赔偿损失的违约责任以及如何承担赔偿责任，需要考虑以下几点：（1）某物业公司是否存在违约行为。（2）业主主张的损失是否符合可预见性原则。（3）业主对于损失的发生有无过错。

首先，关于某物业公司是否存在违约行为。根据双方签订的物业服务合同，物业服务质量参照无锡市普通住宅物业服务等级六级服务标准执行。而根据《无锡市物业服务收费管理实施办法》中关于物业服务等级六级服务标准的规定，某物业公司应当每季对地下管井清理一次，每半年对地下管井彻底疏通一次。根据双方提供的证据，开发商于2021年4月15日将案涉房屋交付给业主，根据上述标准，某物业公司应当迟于2021年10月15日对地下管井进行彻底疏通一次。案涉堵塞的管理虽位于原告家中，但该管道系二楼及以上住户共同使用的主排管道，属于《无锡市物业服务收费管理实施办法》中规定的地下管井范畴。某物业公司应当提供证据证明其在2021年10月15日之前对该管道进行过彻底疏通，但某物业公司未能提供相应的证据。此外，业主存在两次报修记录，某物业公司于业主第一次和第二次报修时既未能认真排除堵塞原因，也未能认真完成疏通义务，而是以管道中有水流出来作为疏通完成的标志。某物业公司的不适当履行导致了第三次大范围的返水而造成本案损失，故某物业公司存在违约行为。

其次，业主主张的损失是否符合可预见性原则。可预见性原则是指违约损失不得超过违约方订立合同时预见到或应当预见到的因违反合同可能造成的损失。本案中，某物业公司作为在无锡地区从事物业服务的专业公司，应当熟知《无锡市物业服务收费管理实施办法》的内容，其应当知晓每半年应对地下管井进行疏通一次。未能疏通将产生堵塞情况导致业主家中装修受损，也符合一般人的认知。本案原告主张的损失也未超过一般装修受损的金额，故原告主张的损失符合可预见性原则。

最后，业主对于损失的发生有无过错。《中华人民共和国民法典》第五百

九十一条第一款规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。具体到本案中，业主在第一次家中出现零星返水时即时向某物业公司报修，某物业公司疏通后告知疏通完成；而后又发生第二次和第三次大规模返水导致产生本案主要损失。业主作为非该管道的使用人，仅能在屋顶发生漏水时才能被动地知道管道发生堵塞，屋顶发生漏水后也及时向某物业公司报修，业主已经采取适当措施防止损失的扩大，故业主对于损失的发生并无过错，某物业公司应承担全部赔偿责任。

编写人：江苏省无锡市锡山区人民法院 谢妍 洪明琪

业主不能以房屋存在一般质量瑕疵问题为由拒交物业费

—— 某物业公司诉李某物业服务合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省中山市第一人民法院(2022)粤2071民初30134号民事判决书

2. 案由：物业服务合同纠纷

3. 当事人

原告：某物业公司

被告：李某

【基本案情】

2020年10月23日，某房地产开发有限公司与李某签订商品房买卖合同，约定李某购买涉案物业，该司于2020年11月30日前将符合本合同约定的商品

房交付李某使用，合同中记载了李某的联系电话。

后某物业公司(甲方)与李某(乙方)签订德云轩前期物业管理服务协议，约定：乙方交纳费用时间按商品房买卖协议或房屋产权证明上的建筑面积计算，从房地产开发公司通知乙方收楼之日起开始计算物业服务费，住宅按建筑面积每月2.8元/平方米收取；逾期交纳物业服务相关费用的，每天按本金加收千分之三的滞纳金。某物业公司称开发商已于2021年12月15日通知李某收楼，李某收楼后未缴纳2022年1月至6月期间的物业服务费，其向李某催收无果，遂诉至法院，主张上述实体权利。

为证明在2022年1月前已通知李某办理收楼手续，某物业公司提交了业主收楼通知书、电话录音、短信截图予以佐证。其中收楼通知书载明某房地产公司通知李某于2022年1月1日办理收楼手续。某物业公司主张开发商已通过挂号信的方式向李某的户籍地寄送上述收楼通知书，挂号信的邮戳时间显示为2021年12月17日，但某物业公司未能提供寄送凭证的原件，李某不确认收到上述收楼通知书。短信截图显示某物业公司员工于2022年1月9日向商品房买卖合同中注明的李某的联系电话发送短信。电话录音反映某物业公司员工分别于2022年1月11日、12日拨打李某预留的联系电话，通知对方办理收楼手续。李某对手机短信及电话录音的真实性不持异议，但认为物业公司并非交房主体，物业公司和其并不存在商品房买卖合同关系，物业公司也没有证据证明其有代开发商交房的代理权。李某主张其是在2022年2月8日前往涉案物业处，当时发现房屋有阳台积水等质量问题，并发送了现场图片给物业公司，要求开发商及物业公司维修整改，开发商及物业公司经维修整改后其才于2022年3月21日接收涉案物业，在2022年3月21日才确认收楼。据此，李某主张其实际收楼时间为2022年3月21日，故其不应缴纳2022年1月至3月期间的物业费。庭审中，李某当庭支付了涉案物业2022年4月至同年9月期间的物业服务费4769.4元。

【案件焦点】

1.涉案物业的开发商及物业公司有无通知业主办理收楼手续；2.涉案物业

的交付时间应如何认定；3.业主能否以房屋存在质量问题为由拒交收楼进而拒绝缴纳物业费。

【法院裁判要旨】

广东省中山市第一人民法院经审理认为：本案中，李某辩称因涉案房屋存在质量问题导致其未能如期收楼，其于2022年3月21日才实际收楼，故其不应支付该日前的物业服务费。本院认为，某物业公司主张其于2021年12月17日向李某的户籍地发送收楼通知书通知李某于2022年1月1日收楼，虽然某物业公司未提交收楼通知书及挂号信函收据原件，但结合某物业公司向李某发送短信的时间及内容，尤其是2022年1月9日的短信中提及“小区开发商和物业公司于2021年12月16日用挂号信的方式向您邮寄了收楼通知书”，李某并未对此提出异议，且短信中提及的邮寄挂号信的时间与某物业公司举示的挂号信的邮戳时间相吻合，综合以上事实本院认定某物业公司的主张具有高度盖然性，故本院采信某物业公司的主张，认定某物业公司及涉案物业的开发商已通过挂号信的方式通知李某于2022年1月1日收楼，李某未按收楼通知书的要求及时办理收楼手续，应承担相应的不利后果。此外，李某抗辩称系因涉案物业阳台存在积水等质量问题才导致其未能如期收楼，本院认为，物业公司并非房屋买卖关系的主体，房屋质量问题与物业纠纷并非同一法律问题，且并非只要存在房屋质量问题，业主就能拒绝收房，只有在房屋主体结构存在质量不合格或者严重影响居住使用的情况下，业主才能拒绝收房。如房屋确实存在一般质量问题，可在保修期内要求开发商修复，但李某不能以房屋存在一般质量问题为由拒绝收房以及拒绝向物业服务企业交纳物业费。李某陈述的房屋质量问题并非主体结构质量问题，李某也未提交房屋存在严重质量问题影响交付的有效证据。故本院认定涉案房屋的交付时间为2022年1月1日，李某应当向某物业公司支付该日起的物业服务费。经核算，李某应向某物业公司支付2022年1月至3月期间的物业服务费为2384.67元(794.89元/月×3个月)。

广东省中山市第一人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百八十五条，《物业管理条例》第四十一条第一款，《中华人民共和国

民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

被告李某于本判决发生法律效力之日起七日内向原告某物业公司支付2022年1月至3月期间的物业服务费2384.67元及违约金。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

在物业服务合同纠纷案件中，经常会发生开发商通知业主收楼，业主收楼时认为房屋存在质量问题，拒绝收楼进而拒绝缴纳物业费的情况。而《物业管理条例》第四十一条第二款规定：“已竣工但尚未出售或者尚未交给物业买受人的物业，物业服务费用由建设单位交纳。”根据上述法律规定，物业公司只能向业主主张房屋交付后的物业费，对于房屋交付前的物业费则无权主张。

故本案的关键就在于认定房屋的具体交付时间。对于房屋交付时间，物业公司认为应当按照通知交付时间认定，即依据《商品房买卖合同》约定的交付时间；业主李某则认为应当按照实际交付时间，即开发商与李某实际办理房屋交接手续的时间。

笔者认为，在房屋仅存在一般质量瑕疵的情况下，因房屋已经具备法定交付条件，如因业主自身原因未按时办理收楼手续，应当由业主自行承担责任，故本案业主李某应从收楼通知书载明的收楼时间开始支付物业管理费。如果房屋确实存在主体结构等重大质量问题导致客观上不满足安全居住的基本收楼条件，则业主拒绝收楼及拒绝支付物业费才具备合理性。需要注意的是，根据相关法律规定，对于业主通常主张的墙体裂缝、层高不足、门窗损坏、瓷砖空鼓、房屋漏水、房屋装修不符合同约定等常见的质量问题仅属于一般质量瑕疵。在商品房存在一般质量瑕疵的情况下，由于并不影响房屋的基本功能，并未导致商品房买卖合同目的不能实现的，不构成严重影响正常居住的根本违约，故业主不得以此为由拒绝收房以及不交纳物业管理费。

另外，业主交纳物业费是基于其接受了物业公司提供的服务，至于房屋是否存在质量问题，与业主是否应该交纳物业费并非同一法律关系，房屋存在质量问题亦非由物业公司造成。业主如发现房屋质量问题可另行向开发商主张质

量瑕疵的保修责任以及相应的损失赔偿。

依照《中华人民共和国民法典》合同编相关规定，当事人应遵循诚信原则，按照约定全面履行自己的义务。如果物业公司没有违反合同内规定的内容，则小区业主就必须依照合同规定缴纳物业费。

编写人：广东省中山市第一人民法院 曹慧星

十八、行纪合同纠纷

37

“网红”主播违约停播，高额违约金如何承担

——某文化传媒公司诉李某行纪合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市大兴区人民法院(2023)京0115民初17649号民事判决书

2. 案由：行纪合同纠纷

3. 当事人

原告：某文化传媒公司

被告：李某

【基本案情】

2020年10月16日，甲方某文化传媒公司与乙方李某签署《艺人直播独家经纪合作协议》。约定：乙方授权甲方为演艺经纪方面的独家代理人。合作期限为2年，自2020年10月16日起至2022年10月15日止。现甲、乙双方就艺人在线演绎独家经纪合作一事，达成如下合作协议，本合同性质：甲乙双方均确认，本合同非劳动合同。保底工资：甲方前期为扶持乙方稳定直播，给予保底工资待遇，给予乙方保底6000元/月，要求乙方每个月直播时长不低于190

小时，每天不低于6.5小时，有效天数不低于26天，乙方按要求完成甲方的要求，后台收到佣金未达到6000元，则甲方补乙方到6000元，如乙方收入超过6000元，则按照双方约定好的分成比例正常分配。乙方在完成规定有效直播时长中不得以游戏、睡觉等消极直播的行为混直播时长，出现上述情况，甲方有权取消保底。乙方在按照本协议的要求完全履行其义务，不存在违约行为，且没有给甲方造成损失的情况下，有权获得甲方一次性支付乙方签约费用4万元。

在线演绎直播佣金：乙方有权取得自己在甲方合作平台收益(扣除企业增值税后)的70%作为报酬；乙方的收益及结算方式：根据甲方合作平台的薪资发放时间，甲方于收到合作平台支付的收益，并完成结算后10个工作日内，以银行转账形式，向乙方支付上一月收益。乙方每个自然月有效直播时间应不低于26个自然日，每日直播时间应不低于6.5小时，每月有效直播时间应不低于190小时。若乙方每月有效直播时间低于190个小时或每天直播时间低于6.5小时的，则甲方有权根据乙方的实际直播时间进行结算。如当月直播时长不达标，自愿延长签约时间，直至达标完整两年直播时长；如乙方因个人原因不能履行本协议直播时长，则乙方需返还甲方支付的签约费用。如连续3个月，未达到本条约定的直播时间或不配合甲方工作安排的，甲方有权单方解除本合作协议，要求乙方返还已收取的费用。乙方应向甲方支付违约金200万元，并另行赔偿甲方损失。2020年10月19日某文化传媒公司向李某支付签约费4万元。

2020年10月至2023年6月，李某在该直播平台进行直播，根据公司回函显示李某2020年11月至2022年10月完成直播时长3442.98小时。某文化传媒公司主张因根据合同约定其应完成时长为4560小时，因此，李某应补时长。2022年11月至2023年4月，仍有631.68小时未补足。但该公司回函显示李某自2021年2月至2021年6月、2021年9月至2023年4月的每月直播时长均未达到190小时。

某文化传媒公司另提交管理平台截图3张，主张通过平台截图可以看出在6月24日、27日至29日李某连续直播时长为23—24小时，通过这些数据可以看出李某并没有进行有效直播，而是登录直播平台进行挂机，而根据该截图显

示6月直播总时长是324小时，但是6月总收益493.77元，大部分天收益是0元，因此李某均非进行的有效直播。

某文化传媒公司称其为了帮助李某带流量支出成本，根据管理平台出具回函称，2020年11月1日至2023年4月，某文化传媒公司为李某所在直播房间号提供推广资源。李某对上述价值额不予认可，其从不知情，而且如果知道也不会同意，该笔费用因何而出，由谁承担，在双方协议中并没有明确约定。另外，某文化传媒公司花费用购买，因此某文化传媒公司没有遭到实际损失，可能只是平台的一种象征性优惠政策。

李某提交其2023年4月与2023年6月的检验报告单两份主张其因2023年3月怀孕且属于高龄产妇，从怀孕初期到现在身体出现多种不适。其另提交平台直播端结算中心与投诉平台截图，主张其2023年4月至6月仍在完成直播，应当得到的提成应为2344.01元、427.75元、296.43元，但某文化传媒公司均未向其支付上述分成，李某称因此其坚持直播到2023年6月，因某文化传媒公司连续三个月未向其支付分成，以及其个人怀孕的原因，决定暂停直播，并非恶意停播。

现某文化传媒公司诉至法院要求解除与李某之间的《艺人直播独家经纪合作协议》并要求李某返还某文化传媒公司支付的签约金4万元，同时出于人道主义角度考虑降低协议约定的200万元违约金要求李某支付违约金10万元。

【案件焦点】

1. “网红”主播违约停播是否承担高额惩罚性违约金；2. 某文化传媒公司主张其为了帮助李某获得流量和热度支出成本的认定。

【法院裁判要旨】

北京市大兴区人民法院经审理认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。本案中，某文化传媒公司与李某签订的《艺人直播独家经纪合作协议》系双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，内容合法有效，双方均应据此行使权利、履行义务。关于某文化传媒公司要求解除其

与李某之间签订的《艺人直播独家经纪合作协议》的诉讼请求，某文化传媒公司主张李某未完成直播时长，构成违约。对此本院认为，合同第7.2条约定，每个自然月有效直播时间应不低于26个自然日，每日直播时间应不低于6.5小时，每月有效直播时间应不低于190小时。李某如连续3个月，未达到约定的直播时间或不配合某文化传媒公司工作安排的，某文化传媒公司有权单方解除本合作协议，要求李某返还已收取的费用并支付违约金200万元，并另行赔偿损失。如当月直播时长不达标，自愿延长签约时间，直至达标完整两年直播时长；如因个人原因不能履行本协议直播时长，则李某需返还支付的签约费用。根据李某提交的其与某文化传媒公司的微信聊天记录，李某在期限内直播时长不达标，后期需要补时长，某文化传媒公司向其要求“按照160小时或者150小时播。补时长也是一个月总的补150小时，每天5小时或者6小时，想休息就6小时，不想休息就5小时，尽量去播够吧”。2022年10月开始每月直播时间已无法达到后续某文化传媒公司要求其达到的每月150小时的时长，在2023年6月之后便停止直播，某文化传媒公司有权根据双方约定主张解除合同。综上，某文化传媒公司有权解除本案涉案合同，李某虽称其愿意在生完孩子并完成恢复之后继续履行案涉协议，但李某已停止直播且其所称的“在生完孩子并完成恢复”的前提以及时间均具有不确定性，故本院对某文化传媒公司要求解除涉案合同的诉讼请求予以支持。合同解除的时间以本案诉状送达李某时间为准。关于某文化传媒公司主张的违约责任。第一，某文化传媒公司要求李某返还违约金4万元的请求，根据合同第7.2条约定，某文化传媒公司有权要求李某返还已支付的费用，本院对该项请求予以支持。第二，某文化传媒公司要求李某支付违约金，合同第7.2条约定的违约金金额为200万元，鉴于某文化传媒公司提交的证据并不足以证明其因李某的违约行为所遭受的具体损失，故本院认为该违约金的标准过高，关于违约金的数额，本院综合考虑合同期限及履行情况、李某的主观过错、李某作为主播的经济价值及收益能力、某文化传媒公司对合同继续履行的合理预期等因素，酌情支持5万元，其余部分，不予支持。

北京市大兴区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百六十五条、第五百六十六条、第五百八十五条之规定，判决如下：

一、确认某文化传媒公司与李某于2020年10月16日签订的《艺人直播独家经纪合作协议》解除，解除日期为2023年10月10日；

二、李某于本判决生效之日起十日内返还某文化传媒公司违约金4万元；

三、李某于本判决生效之日起十日内支付某文化传媒公司违约金5万元；

四、驳回某文化传媒公司的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

随着互联网信息技术的飞跃提升，直播的内容表达形式逐渐被更多人接受，行业的高速发展促进了参与主体——直播传媒公司与“网红”主播的数量不断增加。但在这一过程中，“网红”主播的违约跳槽时有发生，该类诉讼案件也逐年攀升。而在该类案件中，因来源于直播行业，较之传统行业不同又打上了互联网特质的鲜明烙印，在合同的签署、成立、效力、履行、违约行为、收益计算、违约损害赔偿的认定上往往具有自身的特点，需要站在直播行业的视角，结合行业现实情况进行分析判断。“网红”主播违约、跳槽纠纷中高额违约金的适用往往是该类纠纷中最为核心的争议焦点，亦是决定纠纷当事人乃至直播行业发展的重要一环。对于违约金的认定应当综合考虑。

一、违约金的承担需要兼顾直播平台公司与主播个体的双方利益平衡

较之传统企业的不同在于，直播平台公司因“网红”主播违约导致的损失较难有直接证据进行核算，因此设定高额违约金，约束和“网红”主播遵守合作协议，建立、维护平台公司和“网红”主播之间稳定的合同关系，防止在培养“网红”主播使主播获得较高知名度后违约、停播或解约跳槽的情况发生，系切合直播行业特质的合法合理措施。但违约金的数额需要与直播平台公司宣传推广成本、带宽技术成本等自身投入、“网红”主播根本违约所带来的预期利益损失、用户流水情况等综合考虑的结果相符。

还要考虑到，高额违约金是非理性行业竞争的产物。高额违约金对应的

是高投入、高收益。非理性的挖角竞争致使违约金约定的金额逐个攀升，形成行业泡沫；高额的违约金不能真实反映各方的损失和价值，虽在一定程度上抑制主播跳槽，但该抑制也在一定程度上妨碍了“网红”主播的合理流动。并且也要考虑到有时直播平台亦存在一定过错如可能存在欠薪、封禁直播间等问题，会加快促使“网红”主播的跳槽，虽然该过错对不足认定主播违约即合理，但确会在调整违约金时应当综合考虑。

二、违约金的承担以直播平台公司的成本、损失为基础

一般情况下，违约金明显过高请求减少的，应以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚信原则予以衡量。直播平台公司的成本付出如为主播的投流费用、宣传费用等在诉讼中主要依赖经纪公司的举证能力，经纪公司需在日常运营过程中留存如平台运营技术支持、客户支持、自有渠道推广资源，付费和免费外部渠道推广资源，承接商业活动成本、平台推广时间和经济成本等部分证据证明其实际产生了成本。而另外还需要考虑到，主播履行合同期间给公司带来的“收益”，以及假设主播继续履行合同，能够给公司带来的“预期收益”，这就需要综合判断主播的人气和知名度、个人创收能力等特别因素。

从建立健康有序的行业生态角度考虑，出于回归真实、理性的价值导向的考虑，违约金的认定，不应以限制竞争或者以超出支付能力的高额违约金为代价，在严格适用法律的前提下，寻求更符合直播行业特质、更有利于直播行业发展、更具有正向社会价值的适用思路。

编写人：北京市大兴区人民法院 魏若男

主播与经纪公司之间法律关系性质及主播停播、 解绑账号行为之违约责任认定

——某文化传播公司诉李某行纪合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市中级人民法院(2023)粤01民终6051号民事判决书

2. 案由：行纪合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某文化传播公司

被告(上诉人):李某

【基本案情】

2020年5月2日,某文化传播公司与李某签订了《演艺事业推广发展合同》,合作期限自2020年5月2日起至2025年5月2日止。某文化传播公司称李某自2021年6月1日起,未经某文化传播公司书面同意,无故不参加某文化传播公司安排的团队直播、直播带货等演艺活动。某文化传播公司认为李某的行为已构成根本违约,故诉至法院,请求判令解除双方签订的合同、李某向某文化传播公司支付惩罚性违约金、律师费、担保保函费和诉讼费。诉讼中,李某辩称其与某文化传播公司系劳动关系,且某文化传播公司未为其提供培训、策划、推广发展工作,构成根本违约,请求驳回某文化传播公司全部诉讼请求。

【案件焦点】

1. 某文化传播公司与李某是否构成劳动关系；2. 双方违约责任以及违约金数额的认定。

【法院裁判要旨】

广东省广州市白云区人民法院经审理认为：根据双方诉辩意见，本案的争议焦点为：(1)原、被告是否构成劳动关系；(2)双方违约责任以及违约金数额的认定。

关于争议焦点一。本案中，虽然原告对被告有一定程度的管理行为，但该管理行为系直播这一特殊行业所导致，目的是保障双方合作顺利进行。从案涉协议内容及实际履行情况来看，双方就合作内容各自分工，并根据约定按比例对收入进行分配，原告未为被告提供保底收入，被告依据直播等收入取得报酬，双方不具备明显的人身隶属性 and 经济从属性等劳动关系的基本特征。据此，被告主张双方构成劳动关系，理据不足，本院不予支持。

关于争议焦点二。被告主张原告未向其交付合同，从其向原告发出的律师函可知，被告详细列明了案涉合同关于原告权利义务的相关条款，本院对该主张不予采信。虽然案涉合同约定原告担任被告演艺事业的独家全权经纪公司，原告根据被告作为演艺人员的特点对被告的演艺事业做出完整合理的规划，但是在合同实际履行过程中，原告主要安排被告在直播领域发展并为其推广，在长达一年的时间内被告均未提出异议，也无证据证明被告存在其他特长但原告故意忽视并拒不为其安排相关活动，因此被告以原告未安排其他演艺活动为由主张原告违约，理据不足，本院不予支持。关于推广的问题，在原、被告合作期间，被告的粉丝数从几百增至40万左右，被告确认原告为其安排在其他主播的直播间进行直播等方式为被告涨粉，可证明原告履行了推广义务。至于被告在主播A的直播间以刷礼物等方式涨粉的问题，依据现有证据不足以判断该涨粉由被告自身所为或是原告所为，即使被告陈述属实，也无法证明原告存在违约。因此，被告主张原告先行违约，并依此要求解除合同，于法无据，本院不予支持。

关于被告是否构成违约。其一，原告于2021年5月31日对被告作出停播处罚，从处罚通告可知，原告认为停播系因被告个人行为不当所致，被告对此未提出异议，且被告在微信中自称“好好反思”，可知其对处罚内容予以认可。在此情况下，被告主张原告单方作出停播决议构成违约，理据不足，本院不予确认。在停播期间及期满之后，原告询问被告何时回公司，并敦促被告继续履行合同，但无证据证明被告依约参加直播等活动，已构成违约。其二，被告主张原告先行对双方合作的视频平台账号进行解绑，并提交了网页截图予以证明。该截图无法显示是案涉视频平台账号相关截图，退一步而言，即使该截图确为案涉视频平台账号下的相关内容截图，该内容显示解除与被告绑定关系的机构另有其人，无证据证明该机构即为原告。相反，原告在得知被告对案涉账号解绑后，及时与被告沟通并就被告私自解绑提出异议，被告未作辩驳。因此，原告主张被告未经原告允许对双方合作的视频平台账号进行解绑操作，具有高度盖然性，本院予以采信。其三，从原告与被告沟通解绑问题的时间及案涉视频账户提现的时间可知，2021年7月24日及2021年12月12日两次提现发生于被告解绑后，但无证据证明被告向原告支付该部分收入分成。综上，被告的行为已构成根本违约，原告主张解除案涉合同并要求被告支付违约金，合法有据，本院予以支持。原告于2022年7月7日当庭提出解除合同的诉讼请求，被告同意解除，故案涉合同应于当日解除。

关于违约金数额。原告提交了公司支出成本汇总表格拟证明其实际损失情况，但该证据由原告自行制作，且原告确认该部分支出并非均发生在被告一人身上，无法作为违约金的认定依据。依上文所述，被告单方解约且在提取账号收益后未向原告支付收入分成，案涉合同解除也将导致原告在合同有效期内的正常预期收益受损，但是综合考虑案涉合同履行时长、被告知名度及其获取报酬等情况，本院认为合同约定的违约金过高，故酌情调整为被告向原告支付违约金60万元。对于原告主张超出的部分，法院予以驳回。

关于原告主张的律师费、担保费。原告支出的律师费金额未超过律师费收取标准，双方对此两项费用的承担作出明确约定，原告要求被告承担律师费5

万元、担保费5953.43元，合法有据，法院予以支持。

广东省广州市白云区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力 的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判 决如下：

一、某文化传播公司与李某2020年5月2日签订的《演艺事业推广发展合同》于2022年7月7日解除；

二、本判决生效之日起五日内，李某向某文化传播公司支付违约金60万元；

三、本判决生效之日起五日内，李某向某文化传播公司支付律师费5万元、保全担保费5953.43元；

四、驳回某文化传播公司的其他诉讼请求。

李某不服一审判决，提起上诉。

广东省广州市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

“网红”主播是“互联网+”背景下的新兴职业，其与经纪公司之间形成何种法律关系，是劳动合同关系抑或演艺经纪合作关系，当下对此争论不一。笔者认为，“网红”主播与经纪公司之间的法律关系，应基于个案事实具体分析，不能一概而论。

劳动合同关系是为劳动法所调整的权利义务关系，劳动者向用人单位提供劳动力，接受用人单位的管理，从事用人单位指定的工作，并获得劳动报酬和劳动保护所产生的法律关系；演艺经纪合作关系是由民事主体在平等自愿的基础上通过协商设立的民事权利义务关系；相比之下，劳动合同关系为特殊的民事法律关系。那么，关于“网红”主播与经纪公司之间的法律关系性质认定，可通过研究合同订立目的及合同履行过程情况来判断是否符合劳动合同关系，

否则为演艺经纪合作关系。

关于劳动合同关系的认定，其具备以下三个特征：第一，有偿性。劳动者出卖劳动力，用人单位获得对劳动力的支配权，并向劳动者支付劳动报酬，含工资奖金等。第二，组织性。劳动者作为用人单位的成员，将自身的劳动力与用人单位的生产资料相结合，从事用人单位经营的业务范围内的工作。第三，从属性。劳动者与用人单位之间处于不平等的关系状态，劳动者依附于用人单位，无法独立自主开展工作，主要表现在以下两个方面：一方面劳动者的从属性，劳动者应遵守单位的规章制度和工作纪律，开展工作的时间、地点及工作内容都须依照用人单位的管理和安排，用人单位对劳动者具有很强的控制性；另一方面是劳动者的经济从属性，劳动者的收入源于用人单位，其收入的构成与标准都由用人单位统一确定。

首先，本案李某所获得的收入并非某文化传播公司提供，而是取决于李某的直播收入，某文化传播公司未为李某提供固定报酬或保底收入。其次，李某开展的直播工作与某文化传播公司开展的演艺事业规划、演艺培训、形象策划及包装宣传存在较大区别，并非某文化传播公司的经营业务范围。最后，虽李某与某文化传播公司的协议约定“李某须保证每月至少15日、每日至少1小时的有效直播时长”，但李某的工作时间仍然具有较大选择性、灵活性，同时某文化传播公司也未对工作地点做出要求，李某也不用受考勤打卡、迟到旷工等约束，其具有完全的人格独立。另外，李某的收入来源包括直播收益、礼物和打赏等，但均非源于某文化传播公司，李某与某文化传播公司之间平等协商约定不同收益类型按照不同分成比例分配。因此，本案李某与某文化传播公司为演艺事业合作关系。

“网红”主播违约将面临高额违约金赔偿，因此，需要审慎认定“网红”主播的违约责任，这亦是司法实务中的难点。“网红”主播擅自停播、解绑账号、在其他竞争平台直播等行为，无疑都构成违约。本案中，李某抗辩某文化传播公司曾让其停播且某文化传播公司未履行推广义务，但李某在合作期间从未对停播提出异议，并表示会好好反思，在双方合同履行期间，李某的粉丝数量出现明显增长，合同履行期间其亦不曾针对某文化传播公司对其演艺事业规

划提出异议，在双方产生争议后李某再依据上述事由不再履行合同甚至擅自解绑双方的合作账号，故本案认定李某违约。

另外，“网红”主播违约需承担高额违约金，这与直播行业的特点相关，因为主播作为经纪公司的核心资源，经纪公司在前期势必投入平台搭建、包装宣传、引流等较大成本，为主播提供好资源，让主播涨粉以提升流量，最终变现为直播收益。当主播粉丝数量从无到有、从少到多，主播擅自停播、解绑取消账号的行为都可能让经纪公司的投入付诸东流，故设定较高违约金既能对主播起到震慑作用，又能降低经纪公司的潜在风险。但畸高的违约金同样不可取，因此笔者认为，在审理该类案件时应结合合同履行时长、经纪公司前期投入的成本情况、主播直播间粉丝数量、主播知名度、直播收益和打赏情况等因素进行考量，平衡主播和经纪公司之间的利益，根据公平原则、诚信原则，合理确定违约主播所需承担违约金的数额。

编写人：广东省广州市白云区人民法院 傅贤珍 彭洁芳

网络主播签约模式及网络主播与经纪公司法律关系性质认定

— 某文化传媒公司诉廖某行纪合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市朝阳区人民法院(2023)京0105民初16558号民事判决书

2. 案由：行纪合同纠纷

3. 当事人

原告：某文化传媒公司

被告：廖某

【基本案情】

2021年5月27日，主播廖某与其经纪公司某文化传媒公司签订《主播经纪合同》，约定廖某需根据某文化传媒公司要求于指定直播平台进行网络直播演艺及相关活动；合作期限为2021年5月28日至2024年5月27日，廖某收入为直播报酬的30%~40%，剩余直播报酬归某文化传媒公司享有；若廖某无正当理由拒不配合某文化传媒公司的演艺活动安排、直播态度不端正，经某文化传媒公司沟通后仍不改正，因廖某原因导致合同无法正常履行等情况，均属于廖某违约，应向某文化传媒公司支付违约金。合同签订后，某文化传媒公司向廖某支付签约费2万元。根据某文化传媒公司提交的录屏，廖某不配合某文化传媒公司的演艺活动安排，直播态度不端正，且于2022年6月开始，廖某未经某文化传媒公司同意擅自停播，某文化传媒公司据此向廖某出具《警告函》。某文化传媒公司认为廖某的行为构成根本违约，应退还某文化传媒公司签约费2万元并支付违约金12万元。廖某认为双方实际构成劳动关系，案涉纠纷属于劳动争议，应当适用仲裁前置程序，故应驳回某文化传媒公司的起诉。经本院释明，某文化传媒公司未向仲裁机构申请劳动仲裁。

【案件焦点】

1. 网络主播与经纪公司订立合同构成民事合同关系还是劳动关系；2. 违约金如何调整。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：某文化传媒公司与廖某签订的《主播经纪合同》系当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，应属合法有效，双方应全面履行合同义务。《主播经纪合同》明确对廖某直播时长、直播天数进行了约定，根据查明事实，截至2022年6月廖某未再进行直播，存在违约行为，根据合同第10.2条违约责任条款廖某应向某文化传媒公司退还签约费2万元。关于廖某抗辩称某文化传媒公司不符合起诉条件，应裁定驳回起诉，但申请劳动仲裁是提起劳动争议诉讼的前置程

序，经本院释明，某文化传媒公司未向仲裁机构申请劳动仲裁，本院无法直接认定本案系劳动争议纠纷，故对其抗辩意见不予采信；关于廖某抗辩称其停播系针对某文化传媒公司克扣、拖欠工资、严苛管理及停发“签约费”而采取的救济行为，但廖某未进一步举证，如果双方对直播收益分成存在纠纷，可以另行解决。

关于违约金，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，约定的违约金过分高于造成的损失，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。本案中，某文化传媒公司所主张违约金的数额是依据其前期投入及预期利益损失预估得出。但是，首先，某文化传媒公司未举证证明其前期投入成本；其次，在计算可得利益损失时，应当综合运用可预见规则、减损规则、损益相抵规则以及过失相抵规则等，从非违约方主张的可得利益赔偿总额中扣除违约方不可预见的损失、非违约方不当扩大的损失、非违约方因违约获得的利益、非违约方亦有过失所造成的损失以及必要的交易成本。根据查明事实，廖某未按时支付某文化传媒公司直播收益分成，亦存在一定过失。综上，本院在考虑某文化传媒公司损失的基础上，综合考虑双方合同履行情况、当事人过错程度、正常商业交易的风险预估及预期利益等因素，兼顾公平原则和诚实信用原则，依法酌定廖某应向某文化传媒公司支付违约金3万元。

北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百八十四条、第五百八十五条之规定，判决如下：

一、被告廖某于本判决生效之日起七日内退还原告某文化传媒公司签约费2万元；

二、被告廖某于本判决生效之日起七日内支付原告某文化传媒公司违约金3万元；

三、驳回原告某文化传媒公司的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

一、网络主播签约模式

网络主播的签约模式主要可以分成以下三类。

(一)个人主播

个人主播只要在网络直播平台注册账号，就可以进行直播。主播注册账号时不需要与直播平台或经纪公司签订经纪合约，仍需与平台签订入驻协议，但是双方之间的合同通常局限在利润的分配上，对直播时长和劳动量没有限制。该种签约模式争议不大，直播平台只是提供技术中介服务、依约参与主播直播收益分成，主播可以自由选择直播时间和地点。

(二)网络主播与网络直播平台签约

为了保证平台流量的稳定性，直播平台会与主播签约让其成为平台旗下艺人，限制其进入其他竞争平台直播，并约定直播收益的分配方式、违约责任等商业条款，同时平台会对主播直播行为开展全面的管理和监督工作。对于此类新型合约的法律性质究竟是属于民事合同关系还是劳动关系，目前学术界和实务界都存在较大争议。

(三)网络主播与网络经纪公司签约

本案双方所订合同属于该种签约模式，通常主播会与经纪公司签订独家经纪合同，由经纪公司负责主播的全方位培训、包装和发展，主播须在经纪公司指定直播平台进行网络直播活动。主播可以自行选择直播场地，直播时间不固定，双方约定直播收益分成，经纪公司或公会通过约定每月的有效直播天数及每天的有效直播时长来约束主播的直播行为并对主播进行一定程度的管理。

二、网络主播与经纪公司订立合同的法律关系性质

无论是委托、中介还是经纪、合作或者综合性合同，民事合同关系属于平等主体之间的人身和财产关系；劳动关系建立的核心则是从属性，即经济从属性、人格从属性和组织从属性，强调管理与被管理的隶属关系。本案中，网络主播与经纪公司订立的《主播经纪合作合同》属于新类型合同，不应仅从合同名称认定其法律关系性质，还应从合同履行内容综合判断，虽然案涉合同包含

一定程度的管理内容，但是笔者仍倾向于构成平等的民事合同关系，并非劳动关系，因为双方管理与被管理的从属性并不稳定。

在司法实践中，确实存在将网络主播与经纪公司的签约模式视为劳动关系的案例。然而，在判断这种法律关系时，我们通常会从劳动关系确立标准的形式要件出发，但更为核心的是要考察实质要件，即劳动关系中的从属性是否成立。笔者认为该种签约模式在符合原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》^①的认定标准方面存在三个显著的难点。首先，直播地点的灵活性使得传统的“工作地点”概念变得模糊，主播并不完全受控于经纪公司的空间管理；其次，主播的直播行为虽然是经纪公司服务内容的一部分，但并不构成其主营业务的全部，这使得业务组成标准的判断变得复杂；最后，主播的收益主要来源于其网络表演行为的盈利，而经纪公司的收益则基于对这些盈利的抽成，这与传统劳动关系中用人单位无论是否盈利都需要支付劳动者劳动报酬的原则存在差异。

因此，可以从直播地点、是否属于业务组成内容及收益来源三个角度综合认定网络主播与经纪公司订立合同的法律关系性质，以作出更为准确的判断。

编写人：北京市朝阳区人民法院 何方

^①参见原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第一条规定：“用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同，但同时具备下列情形的，劳动关系成立。（一）用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格；（二）用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳动；（三）劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。”

十九、中介合同纠纷

40

中介合同的成立不以委托人最终实现预期利益为前提

——某进出口贸易公司诉王某中介合同案

【案件基本信息】

1.判决书字号

河南省南阳市中级人民法院(2023)豫13民终4451号民事判决书

2.案由：中介合同纠纷

3.当事人

原告(上诉人):某进出口贸易公司

被告(被上诉人):王某

【基本案情】

2020年4月13日,王某(乙方)草拟一份《居间合同》通过微信发送给某进出口贸易公司法定代理人李某(甲方),约定乙方自愿接受甲方委托,负责就某呼吸机采购项目(以下简称该项目),对接甲方和该项目销售单位进行洽谈,向甲方及销售单位提供关于该项目的重要信息,并最终促成甲方与销售单位签订该项目的购买合同。“居间成功”是指甲方与销售单位就该项目签订书面的销售合同。如果居间成功,则甲方应按本协议约定,向乙方支付居间报

酬。若未及时支付，则按未按时支付金额的150%向乙方承担违约金。2020年4月14日将该合同通过微信发送给李某，后李某发送一份盖章的居间合同，将居间成功定义为甲方与销售单位就该项目签订书面销售合同并开始交付货物，其他内容没有修改。某进出口贸易公司于当日即给王某转账20万元，备注诚意金，2020年4月15日给王某转账5万元，备注其他，共计25万元。

另查明，2020年4月13日，某进出口贸易公司与某某公司签订《产品购销合同》，约定订货数量100台，含税单价17600元，金额176万元。某进出口贸易公司于2020年4月14日分三次向某某公司支付528万元。某某公司于2020年5月20日向某进出口贸易公司返还40万元，2020年5月25日返还70万元。2021年10月28日，河北唐山市路北区人民法院出具民事调解书，确认某进出口贸易公司与某某公司2023年4月13日签订的《产品购销合同》解除，某某公司返还某进出口贸易公司货款418万元及利息30万元。

再查明，2020年5月9日，某进出口贸易公司为王某出具证明一份，表示愿对该同志所做工作付出相应的劳动服务报酬。

【案件焦点】

1.案涉双方之间的居间合同应否予以解除；2.对某进出口贸易公司主张王某退还25万元应否予以支持。

【法院裁判要旨】

河南省内乡县人民法院经审理认为：某进出口贸易公司为购买某呼吸机项目，与王某签订的《居间合同》系双方的真实意思表示，合法有效。经王某斡旋，当天某进出口贸易公司即与供货方某某公司签订了《产品购销合同》，应认定为居间成功。在此情况下，请求解除《居间合同》于法无据，法院不予支持。此外，居间人的义务只是向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，促成委托人与相对第三人成功签约。而某进出口贸易公司在居间合同定义中把居间人的义务扩充至“交付货物”，以预期利益作为居间成功的条件，突破了法律对居间人义务的规定。况且，某某公司未供货的原因是某进

出口贸易公司未在约定时间支付货款，现据此要求返还已支付的25万元居间费用，显然与情理相悖。

河南省内乡县人民法院根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第二条，《中华人民共和国合同法》第三十二条、第三十七条、第四百二十四条、第四百二十六条之规定，判决如下：

驳回某进出口贸易公司的诉讼请求。

某进出口贸易公司不服一审判决，提起上诉。

河南省南阳市中级人民法院经审理认为：王某作为中介，为某进出口贸易公司提供并完成了居间服务，某进出口贸易公司应向王某支付居间费。《产品购销合同》是否履行属于合同双方当事人的权利义务，王某作为居间人对合同是否履行并不具有决定权，某进出口贸易公司在王某已经促成合同签订后对该合同条款的修改明显加重了居间人义务，某进出口贸易公司也未提供证据证明双方对该条款的修改进行过磋商，并征得王某同意，故某进出口贸易公司对合同条款的修改对王某不发生法律效力。在王某已经完成居间义务的情况下，某进出口贸易公司主张解除双方之间居间合同并要求王某返还居间费用，一审法院未予支持并无不当，本院予以维持。

河南省南阳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】①

本案在审理中，对于应否支持某进出口贸易公司的诉讼请求，有两种不同观点：

第一种观点认为，王某虽然促成某进出口贸易公司与某某公司签订了《产品购销合同》，但最终没有完成交付货物，故根据某进出口贸易公司修改的

①《中华人民共和国民法典》已将“居间合同”类型表述为“中介合同”。本案遵循裁判时的有名合同类型，表述为“居间合同”。

“居间成功”定义，王某存在违约责任，应支持某进出口贸易公司要求解除《居间合同》诉讼请求，但某进出口贸易公司应当支付王某从事中介活动支出的必要费用。

第二种观点认为，某进出口贸易公司修改后的“居间成功”定义突破了法律对居间合同关于居间人义务的规定，加重了居间人的法律责任，与居间合同的立法精神不符，且最终没有完成货物交付，违约责任在某进出口贸易公司，王某不存在违约责任，故某进出口贸易公司的诉讼请求应予驳回。

笔者同意第二种观点。

首先，居间(中介)合同不能突破法律对居间人义务的规定。根据我国法律的规定，居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。由此可见，居间合同分为报告中介合同和媒介中介合同。所谓报告居间，是指居间人为委托人寻找，寻觅并指示可以与委托人建立合同关系的人，它是直接面向委托人的。所谓媒介居间，是指居间人在委托人和第三人之间互寻、介绍和撮合，不但报告订立合同的机会，还周旋于委托人和第三人之间，促使双方订立合同。前者在于中介人应向委托人提供订立合同的机会，后者强调中介人应在委托人和第三人之间进行斡旋、协助，以促成委托人与第三人订立合同。本案中，某进出口贸易公司委托王某就采购呼吸机项目与销售单位进行洽谈，经王某斡旋，某进出口贸易公司与某某公司签订了《产品购销合同》，并向王某支付居间费25万元，某进出口贸易公司与王某之间成立媒介中介合同，且根据现行法律规定，应认定居间成功。但某进出口贸易公司在居间合同中把居间人的义务扩充至“交付货物”，突破了法律对居间合同关于居间人义务的规定，即某进出口贸易公司以其实现与某某公司签订《产品购销合同》的预期利益作为居间合同成功的条件，无疑加重了居间人的法律责任，与我国居间合同的立法意图、社会发展需要明显不符，不利于切实地保障中介人的合法权益，故该条款应认定为无效。

其次，中介合同的成立不以委托人最终实现预期利益为前提。在居间合同中，委托人最终能否最大限度地实现预期利益，取决于订立合同后委托人与相

对人履行合同的最终效果，非中介人行为可决定。同时，根据法律规定，中介人促成合同成立的，委托人应当按照约定支付报酬，且支付中介报酬的法定条件仅包括：中介合同合法有效；中介人向委托人提供了中介服务；中介人履行了如实告知的义务；中介人促成合同成立。由此可见，居间报酬支付条件成就以委托方与第三人合同订立而非委托方预期利益实现为前提。本案中，某进出口贸易公司与某某公司签订的《产品购销合同》主体分别是某进出口贸易公司、某某公司，王某既非该合同任何一方主体，亦非任何一方的代理人，且某进出口贸易公司也无证据证明是基于中介人的原因导致其与某某公司的合同目的无法实现，故王某促成委托人与相对人成功签约，已经完成了居间义务。同时，某某公司未向某进出口贸易公司供货，系某进出口贸易公司未按《产品购销合同》中约定的时间支付货款而造成的，责任在己方，故某进出口贸易公司以购销合同相对人未供货要求解除与王某签订的《居间合同》等诉讼请求，显然于法、于理、于情相悖，依法应予驳回。

编写人：河南省内乡县人民法院 柴舒婷

中介人违反如实报告义务，无权要求支付报酬

—— 某房产信息所诉张某、丁某中介合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省绍兴市中级人民法院(2023)浙06民终1507号民事判决书

2. 案由：中介合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某房产信息所

被告(被上诉人): 张某、丁某

第三人: 吕某

【基本案情】

张某、丁某为出售某房产,委托某房产信息所提供中介服务。某房产信息所与意向买受人吕某、张某谈好上述房产以172万元价格成交,但张某为了给丁某一个交代,要求原告将书面合同上的成交价写成175万元。2022年1月26日,甲方(卖方)张某、丁某与(乙方)买方吕某签订成交价为175万元的《房地产买卖合同1》,付款方式为2022年1月31日前支付50万元,2022年5月27日前支付45万元并当天完成过户,余款80万元以公积金+商贷组合贷款方式支付,具体放款日期以银行及公积金中心为准。同时,该契约第七条约定:“中介佣金按成交价的1.5%由甲方支付,在合同签订时收取。本合同经双方签章后生效,若双方或单方中途毁约造成买卖中断,经调解无效后,则中介方不承担责任,佣金不予退还,由违约一方支付。”该契约上,原告作为中介方进行盖章。2022年1月27日,因契约所载成交价175万元比实际协商成交价172万元虚高3万元,某房产信息所与张某就第一期付款先付47万元还是50万元产生了争议,同时双方还就中介佣金进行了协商。因某房产信息所要求张某、丁某实际收款47万元但出具50万元收条以及提供征信报告事宜,双方产生了矛盾,故张某称“算了,不卖了”。同日,某房产信息所经营者马某某跟吕某讲征信显示张某、丁某有几十万元网贷以及案涉房产的按揭款80万元,马某某认为因合同金额比实际成交价虚高3万元,张某要求现在打款50万元,万一吕某打完50万元后张某也要求按合同来会说不清,所以还是算了吧。某房产信息所未再通知吕某支付购房款。吕某为购房需要,又在某信息所看到了案涉房产的出售信息,基于对该房产的喜欢,其在某信息所的中介下于2022年2月9日签订了《房地产买卖合同2》。该契约载明房产成交价178万元,付款方式为2022年2月9日付定金10万元,2022年5月27日前付首付68万元并过户,余款100万元由银行贷款方式支付。

【案件焦点】

1.原告某房产信息所是否就有关订立合同事项向委托人如实报告；2.原告某房产信息所是否促成合同成立；3.被告丁某、张某与吕某的行为是否属于“跳单”行为；4.某房产信息所有无适当履行中介义务并要求丁某、张某支付中介报酬。

【法院裁判要旨】

浙江省嵊州市人民法院经审理认为：本案的争议焦点集中在：(1)原告某房产信息所是否就有关订立合同事项向委托人如实报告。(2)原告某房产信息所是否促成合同成立。(3)被告丁某、张某与吕某的行为是否属于“跳单”行为。(4)如果原告某房产信息所享有收取中介佣金的权利，则应支付中介佣金的责任方是否为被告丁某、张某。

关于第一个争议焦点。《中华人民共和国民法典》第九百六十二条规定，中介人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。中介人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，损害委托人利益的，不得请求支付报酬并应当承担赔偿责任。在二手房买卖中，房产转让价格是影响当事人是否买卖房屋的重要因素。原告某房产信息所为促成房产交易，未向委托人之一即被告丁某如实报告案涉房产的实际成交金额为172万元，反而促成签订形式上成交价为175万元的《房地产买卖合同1》共同欺瞒丁某，属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实行为，损害委托人丁某的利益，根据法律规定不得请求支付报酬。

关于第二个争议焦点。《中华人民共和国民法典》第九百六十三条第一款、第九百六十四条中规定，中介人促成合同成立的，委托人应当按照约定支付报酬；中介人未促成合同成立的，不得请求支付报酬。合意的达成是合同成立的要件。本案中，第三人吕某的真实意思表示为以172万元购买案涉房产，与丁某以175万元出售案涉房产的意思表示不一致，买卖双方未达成合意，故案涉房地产买卖合同未成立，中介人不得请求支付报酬。

关于第三个争议焦点。《中华人民共和国民法典》第九百六十五条规定，

委托人在接受中介人的服务后，利用中介人提供的交易机会或者媒介服务，绕开中介人直接订立合同的，应当向中介人支付报酬。本案中，吕某系在另外中介处看到案涉房产后购买，并未利用原告提供的交易机会或者媒介服务，不属于“跳单”，无须向原告支付报酬。

关于第四个争议焦点。基于前面三个争议焦点的阐述，法院认为原告无权请求支付中介佣金，故对应支付中介佣金的责任方是否为被告丁某、张某不再评判。

综上所述，原告的诉讼请求，于法无据，依法不予支持。

浙江省嵊州市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第九百六十二条、第九百六十三条、第九百六十四条、第九百六十五条之规定，判决如下：

驳回某房产信息所的诉讼请求。

某房产信息所不服一审判决，提起上诉。

浙江省绍兴市中级人民法院经审理认为：对一审判决查明的事实予以确认。认为，本案二审主要争议焦点为：某房产信息所有无适当履行中介义务并要求丁某、张某支付中介报酬。根据查明的事实，丁某、张某系案涉房屋共同所有人及共同卖方，吕某系买方，某房产信息所系中介人，从2022年1月26日《房地产买卖合同1》签订过程及合同内容来看，虽然张某、吕某、某房产信息所谈好以172万元成交案涉房产，张某为了给丁某一个交代要求某房产信息所将书面合同上的成交价写成175万元，但某房产信息所作为专业房产中介机构，并未尽到中介机构的如实报告义务，故意向共同出卖人之一的丁某隐瞒房屋实际成交价格，损害了丁某的利益。另外，丁某实际认可的是《房地产买卖合同1》中约定的价格175万元，故买卖双方对房屋成交价格并未达成一致意见，案涉房屋买卖合同也未成立。依照《中华人民共和国民法典》第九百六十二条、第九百六十四条之规定，某房产信息所无权请求支付报酬。至于某房产信息所上诉中所称的案涉房屋存在一房二卖的上诉理由，如前所述，某房产信息所因故意向共同出卖人之一的丁某隐瞒房屋实际成交价格，导致本案买卖双方对房屋成交价格并未达成一致意见，某房产信息所实际并未促成案涉房屋买卖

合同成立，某房产信息所未促成案涉房屋买卖合同成立与此前张某、丁某是否与案外人签订房屋买卖合同并无关联，故此前张某、丁某是否与案外人签订房屋买卖合同并不影响本案审理。

综上，某房产信息所的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。浙江省绍兴市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在二手房交易市场中，房产中介人汇总供求信息、提供交易便利的专业化服务是促成二手房交易的关键。虽然房产买卖缔约的选择权在于客户本人，但其作出缔约与否的选择与判断，离不开中介人的推介与助力。在整个交易过程中，买卖双方均有正当理由信赖中介人在促成缔约完毕时已为其利益保护做到最基本的风险防范。中介人应遵守《中华人民共和国民法典》第九百六十二条的规定，向委托人履行如实报告义务。

中介人不履行如实报告义务的表现分为两种情况。一种是故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，属于一种消极不作为的状态。故意隐瞒属于典型的欺诈，中介人故意隐瞒能够影响委托人决定是否订立合同的信息，以及可能损害委托人利益的信息，直接影响委托人的理性交易判断。成交价格是二手房买卖合同中的重要条款，在委托一方存在两人以上的，中介人应对全体委托人的利益负责。本案中，委托卖房的房主为夫妻二人，即便向其中一人对外认同172万元的交易价格并不当然代表夫妻另一方的意思表示，何况张某明确丁某仅认可175万元的交易价格。案涉《房地产买卖契约1》中交易价格175万元不是张某、吕某、某房产信息所的真实意思表示，买卖双方对房屋成交价格并未达成一致意见，案涉房屋买卖合同也未成立。另一种是故意向委托人提供虚假情况，属于一种积极的乱作为的状态。遵循诚信原则，中介人应保证所提供中介信息的真实性。市场交易实时变更，繁多复杂，不能要求中介人提供的信息100%无差错，但如果知道或者应当知道该信息不具有真实性而告知委托人，属于欺

诈，可以理解为一种积极作为的情形。

中介人违反如实报告义务实质构成根本违约，需要承担违约责任。此处违约责任的承担，并不以损害后果发生为前提，只要中介人故意隐瞒重要事实或者提供虚假情况，在性质上能够损害委托人的利益，不管事实上损害结果是否发生，中介人都应承担违约责任。首先，丧失报酬请求权。委托人可以对方根本违约为由主张解除合同，并拒绝履行支付报酬的义务。若委托人支付中介报酬之后才发现对方有违反如实报告义务情形的，可要求其返还报酬。其次，因中介人违反如实报告义务，致使委托人遭受损失的事实发生的，应当承担赔偿责任，此时构成违约责任与侵权责任的竞合。

编写人：浙江省嵊州市人民法院 许芝悦

中介公司促成当事人签订合同后，当事人 自行协商变更合同条款，仍需支付中介费

—— 某中介公司诉刘某中介合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终4469号民事判决书

2. 案由：中介合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某中介公司

被告(上诉人): 刘某

【基本案情】

2021年6月30日，甲方刘某与乙方某中介公司签订《佣金确认书》，约定：甲方通过乙方的居间服务签订房屋租赁合同，确认服务信息如下：房屋坐落于北京市海淀区某号，佣金金额（居间服务费）为36500元；乙方居间服务的具体内容：（1）提供租赁信息。（2）提供与租赁房屋相关的交易流程、交易风险、市场行情咨询。（3）协助甲方对房屋进行实地查验。（4）协助并促成甲方签订房屋租赁合同，甲方确认乙方已提供上述1、2、3、4项服务，甲方签订房屋买卖合同或者租赁合同，乙方即完成上述第4项服务；甲方承诺于收到首期租金2日内向乙方支付上述佣金，如逾期支付，每逾期一日，须按佣金金额的千分之五支付违约金。

某中介公司称已完成中介服务并促成刘某与现承租方签订《房屋租赁合同》，提供了：（1）微信聊天记录，显示：2021年6月18日，某中介公司员工添加了罗某微信；6月20日向罗某推荐了涉案房屋；6月28日，罗某表示“我觉得要租今天下午那个房子了，您帮忙问一下细节吧”。随后双方开始就该房屋进行协商，并约定6月29日和业主现场看房。（2）看房现场视频，拍摄于2021年6月29日带罗某现场看房过程中。（3）租房群微信记录，显示：于2021年6月29日建立微信群，群内人员有刘某、罗某、某中介公司员工，三方约定于2021年6月30日签署租赁合同。（4）《房屋租赁合同》首页复印件，相关内容为：甲方刘某将涉案房屋出租给乙方罗某，租赁建筑面积约为300平方米，租期为三年，自2021年7月1日至2024年6月30日，租金为4元每天每平方米，每两年递增5%。某中介公司称拍摄于承租双方签订合同现场，只拍了第一页，刘某就不让拍了。

审理中，刘某提供了：（1）刘某与罗某于2021年7月10日签订的《房屋租赁合同》，约定：甲方刘某将涉案房屋出租给乙方罗某，租赁建筑面积约为247平方米；租期为三年，自2021年7月10日起至2024年7月10日止；租金为4元每天每平方米，每两年递增5%。（2）刘某与罗某的微信聊天记录，显示：2021年7月2日，罗某称“我就一个诉求，按实际面积算房租。建筑多

少，公摊多少，20平方米我就能多出一间教室”，“如果超出3%我就不租了”，刘某表示同意。

【案件焦点】

刘某在中介公司促成合同后与承租人协商变更合同条款另行签订合同，是否需要支付中介费。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：某中介公司提供的证据足以证实该公司已为刘某提供了中介服务并促成刘某与承租方就涉案房屋签订了租赁合同。某中介公司与刘某签订《佣金确认书》后，刘某应当向某中介公司支付中介费，某中介公司要求刘某支付中介费36500元的理由正当。刘某认可曾签订房屋租赁合同，因承租方对建筑面积提出异议，故又重新签订房屋租赁合同，刘某以房屋建筑面积减少为由，否认某中介公司为其提供中介服务并拒绝支付中介费，于法无据。刘某未支付中介费，已构成违约，应当承担违约责任。故刘某应支付某中介公司中介费36500元。

北京市海淀区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百八十五条之规定，判决如下：

一、刘某于本判决生效后七日内向某中介公司支付中介费36500元并支付违约金(以36500元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率二倍计算，自2021年7月12日起至实际支付之日止)；

二、驳回某中介公司的其他诉讼请求。

刘某不服一审判决，提起上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：某中介公司已为刘某提供了中介服务并促成刘某与承租方就涉案房屋签订了租赁合同，《佣金确认书》确认的付款条件已经成就，刘某应该向某中介公司支付中介费。刘某以承租人对建筑面积提出异议，又重新签订房屋租赁合同为由主张某中介公司事实上并未促成签订房屋租赁合同，于法无据。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第九百六十一条规定，中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。《中华人民共和国民法典》第九百六十五条规定，委托人在接受中介人的服务后，利用中介人提供的交易机会或者媒介服务，绕开中介人直接订立合同的，应当向中介人支付报酬。

自《中华人民共和国民法典》出台以来，在合同编中对于不同种类的合同分门别类作出了详细规定，而中介合同也被作为独立的合同类型进行了详细的法律规定，值得深入研究。本案中，中介公司为刘某提供中介服务，而刘某以自己最终签订的合同和中介公司促成的合同内容不一致为由，主张中介公司未完成中介服务，未履行合同义务。因此，如何在审判中准确把握中介服务是否履行的相关认定标准，如何认定委托人绕开中介人直接订立合同，是本案中值得研究探讨的重点问题。

一、中介服务是否完整履行的认定标准

从中介合同的定义来看，中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。因此中介服务的核心在于中介公司是否能为委托人寻找到合同相对方，是否能促成委托人合同的订立。在本案中，中介公司从添加承租人微信开始，向承租人介绍涉案房屋信息，与双方协商现场看房时间、主持现场看房并且拍摄录像、见证双方签订合同文本，到此为止已经完整地完成了中介服务。从《佣金确认书》的内容来看，中介公司也已经完成了确认书载明的全部工作：（1）提供租赁信息。（2）提供与租赁房屋相关的交易流程、交易风险、市场行情咨询。（3）协助甲方对房屋进

